

१.१ परिचय(Introduction)

सामान्य अर्थमा समानता भनेको बराबरी हो अर्थात मानिसहरूका बीच धर्म, वर्ण लिङ्ग, जात जाति, राजनीतिक आस्था वा यस्ता आधारमा हुने भेदभाव रहित अवस्था हो । समानताको अवधारण मानविय मुल्य, मान्यता, मर्यादा र प्रतिष्ठाका आधारमा सबै व्यक्तिहरू अन्ततः समान छन् भन्ने तथ्य परक मान्यतामा आधारित छ । न्याय कानूनको क्षेत्रमा समानता भन्नाले राज्यद्वारा गरिने व्यवहारमा जातजाति, रंग, लिंग धर्म वा वैचारिक आस्थाका आधारमा नागरिकका हकमा समान रुपले लागू हुने कानून बनाउनु, समान व्यवहार गर्नु र राज्यबाट उपलब्ध हुनसक्ने सेवा सुविधाहरू समान रुपले वितरण गर्नु हो ।

प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री रुसोका अनुसार- मानिसहरूका बीच दुई प्रकारका विभेदहरू रहेको पाइन्छ । प्राकृतिक र कृत्रिम प्रथम प्राकृतिक अन्तर्गत प्राकृतिकले नै सबै व्यक्तिहरूलाई समान बनाएको छैन र व्यक्तिहरूका बीच प्राकृतिक रुपमा नै विभेद रहेको छ, जसलाई मानवीय प्रयासद्वारा हटाउन सकिँदैन जस्तो: महिला र पुरुष, सबल र कमजोर अनि सपाङ्ग र अपाङ्ग आदि । दोस्रो कृत्रिम अन्तर्गत प्रकृतिले समान बनाएको कुरामा पनि मानवीय प्रयासबाट असमान बनाएको छ, यसलाई मानवीय प्रयास स्वरुप हटाउन पनि सकिन्छ जस्तो: धनी र गरीब, सम्पन्न र बिपन्न, ठूलो र सानो, छुत र अछुत अनि शिक्षित/साक्षर र निरक्षर आदि । यी पछिल्लो असमानताहरू मानव निर्मित असमानताहरू हुन र मानवीय प्रयासबाट यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ ।

समानताको अवधारणा वर्तमानको उपज नभई मानव सभ्यताको उदयकालदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा इच्छित र प्रयास गरिएको हो । समानता मानव मात्रको रहन र वाध्यताको विषय पनि हो । यो यस कारणले हो कि सबै मानिसकै रुपमा जन्मन्छ र मानिसकै रुपमा यसको अवसान पनि हुन्छ । प्रकृति र मात्रामा फरक रहेपनि हरेक मानिसमा इच्छा हुन्छ । व्यक्तित्व विकासको रहन हुन्छ, संवेदनशीलता हुन्छ, मर्यादित र सम्मानपूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भई जीवन निर्वाह गर्ने लक्ष्य हुन्छ । यो सबैको प्राप्ति र सन्तुष्टि समानताको वातावरणमा मात्र सम्भव हुन्छ । भेदभाव रहितको व्यवहारमा मात्र सुगम हुन्छ । त्यसर्थ विभिन्नताका बावजुद सकेसम्म बढी हदमा समानताको वातावरण व्यवस्था गर्न मानिस प्रयत्नशील हुन्छ ।

विभेद गर्नु त्यसै पनि नकरात्मक हो । किन भने मौलिक मानव अधिकारको रुपमा मानिस समानताको हकको प्रत्याभूति चाहन्छ । प्रशस्त अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिक व्यवस्थापनहरू तथा राष्ट्रिय संविधान र विभिन्न कानूनद्वारा यसको प्रत्याभूति पनि गरिएको हुन्छ । तर अर्को शास्वत सत्य के हो भने दुई वा दुई भन्दा बढी मानिस, प्राकृति, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, हैसियत, क्षमता सोचाई रहन आदिका कारण कहिल्यै समान हुँदैनन् । समान हुँदैन भनेर बस्दा पनि असमानताको खाडल यति गहिरो र व्यापक हुन पुग्दछ की सामाजिक नैराश्यता, विद्वेष, कलह, बिद्रोह आदिले जन्म लिन पुग्दछ । तसर्थ त्यस्तो असमानलाई अर्को वर्ग समान गर्न कहिले काही दोस्रो वर्गको विरुद्ध र पहिलो वर्गको पक्षमा भेदभावपूर्ण व्यवहार आवश्यक हुन्छ । यो विभेद गर्नु नराम्रो पक्ष भए पनि सकारात्मक नै मानी असमानलाई अर्को समान गर्न कहिले काहीँ दोस्रो वर्गको विरुद्ध र पहिलो वर्गको पक्षमा भेदभावपूर्ण व्यवहार आवश्यक हुन्छ । यो विभेद गर्नु नराम्रो पक्ष भए पनि सकारात्मक नै मानिन्छ ।

समानताको सिद्धान्तहरू मध्ये व्यक्ति व्यक्ति बीचको औपचारिक समानता समानताको एक पक्ष हो र समूह समूह बीचको सारभुत समानता अर्को पक्ष हो । यसै समूहको समानताको धारणाको फलस्वरुप सकारात्मक विभेदको धारणाले जन्म लिएको हो, कारण एउटा समूहलाई समावेश, बाहेक, रोकावट वा बिशेष छुट दिएर अर्को समूह समान गराउने प्रयास गरिन्छ । यसले समूहमा रहेको विभेद निराकरणको लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ । साथै समानताको अनुशरण गर्दै सामाजिक न्यायको लागि पृष्ठपोषणको काम गर्दछ । यस अर्थमा हेर्दा संविधान भित्रैबाट समाजमा रहेको असमानताको स्थिति हटाउने वैधानिक संयन्त्रको रुपमा यसलाई हेर्नु पर्दछ ।

विधिशास्त्री डायसीद्वारा प्रवर्तित कानूनको अगाडि समानताको परम्परागत दृष्टिकोणले केवल समानता, कानूनको सर्वोच्चता, कानूनको समान संरक्षण आदिलाई कानूनको शासनसम्बन्धी सिद्धान्त अन्तर्गत समेट्दछ भने यस सम्बन्धी नवीनतम् धारणाले, समानता, पहुँच, सहजता र सारभूत समानतालाई समेट्दछ । त्यसर्थ, सकारात्मक विभेद मुलभूत रुपमा सशक्तिकरणको अवधारणा हो ।

१.२ समस्याको कथन(Statement of the problem)

समानताको हक र सकारात्मक विभेद आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अपरिहार्य रहेको छ । यहि देशको समग्र विकासलाई समुचित महत्व दिने हो भने समानताको हक र सकारात्मक विभेदको नीति राज्यले अवलम्बन गर्न अनिवार्य छ । त्यसलाई सार्थकता दिन संविधान, कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था हुनुका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त गरिनुका साथै विभिन्न सन्धि महासन्धिहरुको अनुमोदन गरी तिनको कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धता अनुरूप राष्ट्रिय कानूनहरुको निर्माण र संशोधनको प्रयास जारी छ । त्यसै गरी अदालतले पनि सक्रियता देखाउँदै आएको छ । यसरी सकारात्मक विभेद तथा समानताको अदालतले पनि सक्रियता देखाउँदै आएको छ । यसरी सकारात्मक कायम राख्ने तथा समानताको हकको समस्याको समाधान गरी यसलाई उचित रुपमा कायम राख्ने प्रयासको सँगसँगै सामाजिक न्यायका गम्भीर प्रश्नहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । यस अनुसन्धानमा निम्न लिखित समस्याहरुलाई मुलरुपमा उठाउने प्रयास गरिएको छ ।

- क) के नेपालमा प्रचलित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानहरु समानताको हक र सकारात्मक विभेदको लागि पर्याप्त छन् ?
- ख) के अदालतले समानताको हक र सकारात्मक विभेदलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्रको निर्माण गराउने दिशामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ ?

१.३. अध्ययनको उद्देश्य (Objective to the study)

प्रस्तुत समानताको हक र सकारात्मक विभेद सम्बन्धी विषयलाई (Internship) शोधपत्रको माध्यमबाट विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा पुर्‍याई यस विषयमा देखिएका समस्या समाधानका सन्दर्भमा ठोष सुभाव सल्लाह प्राप्त गरी राष्ट्रिय नीति निर्माण जनमत जुटाउन समेत यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसको अलवा अन्य उद्देश्यहरु निम्न छन्:-

- क) नेपालमा समानताको हक र सकारात्मक विभेद सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी अवधारणाको व्याख्या गर्नु ।
- ख) समानताको हक र सकारात्मक विभेदको विषयमा न्यायपालिकीय दृष्टिकोणको सन्दर्भमा विवेचना गर्नु ।
- ग) अध्ययनको आधारबाट यस विषयमा देखा परेका समस्याहरु औल्याई समाधानका उपायहरु प्रस्तुत गर्नु ।

१.४ अध्ययनको महत्व (Importance of the Study)

कानूनी स्नातक तह (LLB) को तेश्रो वर्षको अनिवार्य विषयको प्रस्तुत शोधपत्रको लागि मुख्य रुपमा तयार पारिएको हुँदा पाठ्यक्रमको आंशिक उद्देश्य पूर्ति गर्नु यसको प्राथमिक उद्देश्य भए तापनि यसको महत्व त्यसैमा मात्र सीमित हुने देखिँदैन । यस अध्ययनले हाम्रो समाजमा रहेको विभिन्न जातिय, लैङ्गिक, वर्गीय भेदभावको विषय बस्तुहरुको पहिचान गर्ने त्यससँग सम्बन्धित कानूनी संरचनाहरु पहिल्याउने, सार्थक समानताको हक र सकारात्मक विभेदको सन्दर्भमा अदालतले खेलेको भूमिका पहिल्याउने समेत प्रयास गरिएको छ । समानताको हक र सकारात्मक विभेदको आरक्षणबाट विद्यमान असमानता तथा विभेद हटाउन र अभि प्रभावकारी बनाउन के-के गर्नुपर्छ ? भन्ने

बारेमा चर्चा गरिएको छ । प्रस्तुत विषयमा चासो राख्ने व्यक्ति, कानून, व्यवसायी, कानूनविद्, सर्वसाधारण र अनुसन्धानकर्ताको लागि महत्वपूर्ण श्रोत सामग्री हुनेछ ।

१.५ अध्ययनको क्षेत्र (Field of Study)

जुनै पक्षको पनि आफ्नो क्षेत्र रहेको हुन्छ यस शोधपत्रको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ त्यो निम्नअनुसार रहेको छ.

- १) राजनीतिक क्षेत्र
- २) सामाजिक क्षेत्र
- ३) आर्थिक क्षेत्र
- ४) कानूनी क्षेत्र

१.६ अध्ययन पद्धति (Methodology of the study):

प्रस्तुत अध्ययन सैद्धान्तिक अध्ययन पद्धति (Doctrinal Research method) मा आधारित छ । अध्ययन दुवै प्राथमिक (संविधान, ऐन, नियम तथा सर्वोच्च अदालतका फैसला) र माध्यमिक(पुस्तक, लेख, रचना, प्रतिवेदन इत्यादि) श्रोतहरूलाई आधार बनाई गरिएको छ । यस्ता सामग्रीहरू नेपाल क्याम्पस पुस्तकालय, केन्द्रीय कानून पुस्तकालय, सर्वोच्च अदालत तथा न्यायसेवा तालिम केन्द्र पुस्तकालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पुस्तकालय र विभिन्न वेबसाइटहरूबाट संकलन गरिएको छ । प्रस्तुत अध्ययनको अध्ययन पद्धति मूलतः वर्णनात्मक र विश्लेषणात्मक रहेको छ ।

१.७ सहित्यका पुनर्बलाकन (Review of Literature)

प्रस्तुत शोधपत्रमा विशेष गरी समानताको हक र सकारात्मक विभेदको सन्दर्भमा नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी स्थिति झल्काउने विषयमा केन्द्रित हुँदा २००४ सालको संविधान देखि हालसम्मको संविधान, संवैधानिक कानून (सुरेन्द्र भण्डारी), संवैधानिक कानून (फडिल), संवैधानिक कानून (डा.चन्द्रकान्त ज्ञावली), लोकतान्त्रिक संवैधानिकका आधार(अग्रसारथी प्रकाशन), समानताका हक विषयक कार्यपत्र -कल्याण श्रेष्ठ) मुख्य सामग्रीको रुपमा उल्लेख गरी तत् सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको महत्वपूर्ण फैसलाहरूसमेतलाई मुख्य सामग्रीको स्रोतको रुपमा लिइएको छ ।

१.८ अध्ययनको सीमा (Limitations of the study)

समानताको हक र सकारात्मक विभेद एक सामाजिक अध्ययनको विषय भएकोले जटिल, व्यापक, बृहत विषयबस्तु भएका कारण सम्पूर्ण विषयबस्तुहरू प्रस्तुत छोटो शोधपत्रमा समेट्न नसकिने हुनाले यसको विस्तृतीकरण तर्फ अध्ययन नगरी अवधारणा पहिल्याउन आवश्यक पर्ने विषयबस्तुहरू मात्र प्रस्तुत अध्ययनमा समेटिएको छ । समानताको हक र सकारात्मक विभेदको सन्दर्भमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन र विश्लेषण, यस सन्दर्भमा नेपालको संवैधानिक, कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन र विश्लेषण, यस सन्दर्भमा नेपालको संवैधानिक, कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसलाहरू संक्षेपमा अध्ययन गरिएको छ ।

१.९ अध्ययनको संरचना (Organization of the study)

प्रस्तुत अध्ययनलाई पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो परिच्छेद अध्ययनको परिचय रहेको छ । पद्धति, साहित्य सामग्रीको समिक्षा, अध्ययनको सीमा र संगठनको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

परिच्छेद दुई समानताको हक र सकारात्मक विभेदको अवधारणात्मक पक्षसँग सम्बन्धित रहेको अ । जस अन्तर्गत सैद्धान्तिक अवधारणा समानताको सन्दर्भमा वर्ग र वर्गीकरण सम्बन्धी अवधारणा, वर्गीकरणका विविध आधारहरू, सकारात्मक विभेदका उपायहरू आदिको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

परिच्छेद तीन समानताको हक र सकारात्मक विभेद सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भएको व्यवस्थाको र केही प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थापनको संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

परिच्छेद चार समानताको हक र सकारात्मक विभेदको सम्बन्धमा नेपालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित केही सिद्धान्तहरूको उल्लेख गरिएको छ । अन्तिम अर्थात् पाँचौँ परिच्छेदमा अध्ययनको आधारमा देखिएको समस्याहरूलाई पहिचान गर्दै निष्कर्ष र सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

परिच्छेद-२

समानताको हक र सकारात्मक विभेदको अवधारणा

२.१ सैद्धान्तिक अवधारणा

सबै मानिस जन्मदा स्वतन्त्र हुन्छन्, सबैको उत्तिकै आत्मसम्मान र मर्यादा हुन्छ । भन्ने सिद्धान्तबाट समानताको अवधारणा अभिप्रेरित छ । Black's law dictionary ने Equality is the condition of processing substantially the same rights privileges and immunities and being liable to substantially the same rights privileges and immunities and being liable to substantially the same duties^१ भनी परिभाषित गरेको छ ।

वेलायतका प्रख्यात विधिशास्त्री ए.भि. डायसीको कानूनी राज्यको सिद्धान्तको दोश्रो शर्त Equality of II personas in the eye of law हो । अथवा कुनै पनि मानिस कानून भन्दा उच्च हुन सक्दैन । कानूनका दृष्टिमा सबै समान छन् । कानूनको अख्तियारी विपरीत काम गर्ने पदाधिकारीदेखि कानूनको अवज्ञा गर्ने सामान्य कृषक सम्मले एकै प्रकारको अदालतबाट सजायको भागी हुनु पर्दछ^२ भन्ने हो ।

समानताको हकलाई शास्वत (Perennial) र सर्वव्यापी (Universal) को रूपमा मान्ने गरिन्छ । अर्थात् Right to equality is a ubiquitous right and it must be present wherever law makes its appearance^३ यसै कारण विश्वका प्राय सबै देशहरूले समानताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमै उल्लेख गरी संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको पाइन्छ । यहाँ सम्मकी यसको प्रस्तुतिकरणमा पनि खासै भिन्नता देखिँदैन । उदाहरण स्वरूप नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन । समानताको धारणा सम्बन्धमा अमेरिकी संविधानको चौधो संशोधनमा यस्तो भनिएको छ- No state shall deny to any person within its jurisdiction the equal protection of law^४ यसै गरी जर्मनी, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाका संविधानहरूमा Quality before the law राखिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा ७ तथा मानव अधिकारको घोषणापत्र, १९४८ को धारा ७ मा पनि Equality before the law लाई सुनिश्चित गरिदै Equal protection of law लाई कसैका हकमा विभेद नगरिदै प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ ।

उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानहरूका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रिय कानून र तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरूको अध्ययनबाट समेत संवैधानिक विधि शास्त्रीय समानताको सिद्धान्त अन्तर्गत आपचारिक र सारवान गरी दुई अवधारणाहरूको अध्ययन गर्ने गरिएको पाइन्छ । समानता भन्ने शब्द विधिशास्त्री ए.भि.डायसीले प्रतिपादन गरेको कानूनको राजको दोश्रो नियममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तसर्थ, यसलाई कानूनी राजको एउटा नियमको रूपमा अंग्रेजी कमन ल प्रणालीमा अंगालिएको छ र यसै प्रणालीको उपजको रूपमा लिइएको पाइन्छ ।

समानताको हकको प्रथम शर्त कानूनको दृष्टिमा अर्थात् कानूनको अगाडि समानता पूर्ण नीति र व्यवहारको सुनिश्चितता हो । अर्थात् राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुविधा, अवसर, सहभागिता आदिमा कुनै धर्म, लिंग, जातजाति उत्पत्ति, भाषा, वैचारिक आस्था आदिका आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगरिनुलाई यस अवधारणा अन्तर्गत राखिन्छ । यसैले यसलाई नकरात्क दृष्टिकोण भन्ने गरिन्छ ।

१. Black's law dictionary Hc Black 9 edited by st.paul) west publishin co. 1990, p536

२. कल्याण श्रेष्ठ, भरतराज उप्रेती समेत (सम्पादन) नेपालको संवैधानिक कानून पिडित, २०१४, पृष्ठ १८९.

३. Purna Man Shakya, 'Equality, lassificatio, Protetive Discrimination: A Comparative Perspective', 'ESSAYS ON CONSTITUTIONAL LAW, (Nepal Law Society, 1998) p.28

४. Supra Note 2

विद्वान ए.भि. डायसीले कानूनको दृष्टिमा समानतालाई अभ्र फराकिलो पार्दै As the equal subjection of all classes to the orainary law of the land and administered by the ordinary law courts^४ लेखेका छन् ।

राज्यको कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्य वा व्यवस्थापिकले जारी गरेको कुनै कानूनबाट नागरिकहरुको बीच असमान व्यवहार हुन जाने भएमा त्यो असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ ।

२.२ समानताका धारणाहरु (Approaches of Equality)

समानताका प्रमुख दुई धारणाहरु रहेको छन्, जुन निम्न छन् ^५:-

क) औपचारिक धारणा (Formal Approach):

यस अवधारणालाई Aristotle को समय देखिकै पश्चिमी विचारको निरन्तरता मानिन्छ । समानता सम्बन्धी यो प्राचिन धारणा हो । यसले मानिसहरुका बीच हुन सक्ने शारीरिक, मानसिक एवं यस्तै अन्य असक्षमताहरुतर्फ ध्यान दिँदैन । समानताका लागि समान र असमानताका लागि असमान व्यवहार यसको प्रमुख सिद्धान्त रहेको छ । यस धारणाका अनुसार महिला र पुरुष दुवै प्राप्त अवसरको फाईदा लिनका लागि समान रुपमा सक्षम मानिन्छन् । यस धारणा अन्तर्गत महिला र पुरुष, धनी र गरीब सक्षम र असक्षम, सवल र निर्वल सपाङ्ग र अपाङ्गहरुका लागि अलग अलग कानूनको व्यवस्था गरिएको हुँदैन । सबैका लागि एउटै कानून हुन्छ र सो कानूनबाट प्राप्त अवसरका लागि सबै समान रुपमा सक्षम रहेको मानिन्छ । वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८(१)(२)(३)(४)(५) का व्यवस्थाहरु औपचारिक समानताका व्यवस्थाहरु हुन् । यस सिद्धान्तलाई Monistic Approach पनि भनिन्छ । तर यसको अर्थ भने यो होइन कि राज्यले कानूनको वर्गीकरण गर्न सक्तैन । हाम्रो आवश्यकताहरु यति विविध र जटिल छन् की सम्पूर्ण देसवासीहरुलाई समान रुपले लागू हुने कानून मात्र बनाएर हाम्रो व्यवहार चल्न सक्तैन । निरपेक्ष समानता र एकरूपता न सम्भव छ न वाञ्छनिय नै । कुनै एउटा समुदाय, वर्ग वा समूहको आवश्यकता पूरा गर्न बनेको कानूनले अर्को समुदाय, वर्ग वा समूहका मानिसहरुको समस्या समाधान हुँदैन । किसान र औद्योगिक मजदुरका लागि एउटै कानूनले उनीहरु दुवै समूहको आवश्यकता पूरा गर्न सक्तैन । कानून बनाउने र लागू गर्ने कुनै खास उद्देश्य वा प्रयोजन हुन्छ । त्यसर्थ राज्यले देशका भिन्न भिन्न समुदाय, वर्ग वा समूहको समस्या समाधान गर्न वा आवश्यकता पूरा गर्न भिन्न भिन्न कानूनहरु बनाउन आवश्यक हुन्छ । कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानको लागि कुनै विषेश कानूनी व्यवस्था गर्न विधायीका सक्षम हुन्छ र त्यसो गर्दा विधायिकाले त्यो कानून देशका नागरिकहरु मध्ये कसलाई लागू हुने र कसलाई लागू नहुने भनी छुट्याई नागरिक एवं कानूनको वर्गीकरण गर्न सक्तछ । यसलाई वर्गीकरणको सिद्धान्त भनेर भनिन्छ । तर राज्यले जसरी मन लाग्यो त्यसरी कानून वर्गीकरण भने गर्न सक्तैन । वर्गीकरण विवेकपूर्ण हुनु पर्दछ । त्यसैले यसलाई विवेकपूर्ण वर्गीकरणको सिद्धान्त (Theory of Reasonable Classification) भनेर भनिन्छ ।

यसमा सामान्यतः संविधानले नै निषेध गरेको धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने गरी कानूनको वर्गीकरण गर्न राज्यले सक्तैन । निम्न आधारहरु विद्यमान रहेको अवस्थामा मात्र उक्त कानूनको वर्गीकरण गर्न राज्यले सक्तैन । निम्न आधारहरु विद्यमान रहेको अवस्थामा मात्र उक्त कानूनको वर्गीकरण विवेकपूर्ण (Reasonable) मानिन्छ ।

५. AV Dicey, INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE LAW OF THE CONSTITUTION NINTH ed. (Macmillan and co. Ltd. 1952) p. 202

६. प्रकाश पण्डित, समानताको हकको परिप्रेक्षमा सकारात्मक विभेद एक चर्चा, न्यायदूत, नेपाल बार एसोसिएशन अंक १७४, पृष्ठ ९४, २००८

- कानून वर्गीकरण गर्नुको कुनै बोधगम्य आधार (Intelligible Differentiat) स्पष्ट छ ।
- वर्गीकरण गरिएको कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक (Rational) सम्बन्ध देखिन्छ र
- कानूनी वर्गीकरण (Lawful Classification) छ ।

यसरी कानून बनेमा कानूनले वर्गीकरण गरेको वर्ग, सम्प्रदाय वा समूहको आधार विवेकपूर्ण (Reasonable) छैन भन्ने लागेमा सो कुरा स्पष्ट रूपमा खोली उक्त कानूनको न्यायीक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्दछ र सो कुराको प्रमाण समेत सो निवेदन दिने व्यक्तिले नै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । यसमा अदालतले सधैं उक्त कानून संवैधानिक छ भनी अनुमान गर्दछ ।

ख) सारवान धारणा (Substantive Approach) :

समानता सम्बन्धी यो नयाँ धारणा हो, जुन वर्तमानमा क्रमशः विकसित हुँदै गइ रहेको छ । यस धारणालाई अनेकताको धारणा वा सिद्धान्त (Pluralist Approach) भनेर भनिन्छ, किनकी यस सिद्धान्तले समाजमा रहेका अनेकतालाई स्वीकार गरी सोही अनुसार उपचारको खोजीमा जोड दिन्छ । सारवान समानताको समाजमा रहेका महिला, गरिब, असक्षम, असहाय, अपाङ्ग एवं आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा कमजोर एवं पछाडि परेका वर्ग, सम्प्रदाय र समूहका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई राज्यको विशेष पहलद्वारा समाजका अन्य सक्षम र सवल व्यक्तिहरु सरह राज्यद्वारा प्राप्त अवसरमा समान रूपमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दछ । सारवान समानताको मुख्य उद्देश्य समाजका सक्षम र असक्षम, सवल र निर्वल, शिक्षित र अशिक्षित, धनी र गरीब, सहाय र असहाय, सपाङ्ग र अपाङ्ग, महिला र पुरुष अनि यस्तै अन्य आधारमा रहेको सारवान असमानतालाई हटाई सारवान रूपमा नै समानता कायम गर्नु रहेको छ । यसका लागि महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्थामा यस सिद्धान्तले जोड दिन्छ । वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३ को व्यवस्था सारवान समानताको व्यवस्था हो ।

Formal Approach ले कानूनले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्नमा रोक लगाउँदछ तर सारवान समानताले यी आधारहरुमा समेत कानूनले नागरिकहरुका बीच भेदभाव गर्नमा सहमति प्रदान गर्दछ । तर त्यसका लागि खास आधार एवं कारणहरु विद्यमान हुनु पर्दछ, जसलाई तल विस्तृत रूपमा चर्चा गरिने छ । यसरी यस सिद्धान्त अनुसार राज्यले कानूनद्वारा नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको

आधारमा भेदभाव गरी कानून निर्माण गरेमा त्यसलाई Suspect Classification भनिन्छ र उक्त कानून न्यायिक परीक्षणका लागि अदालतमा प्रवेश गरेमा अदालतले यसलाई Strict Scrutiny Test अन्तर्गत परीक्षण गर्दछ । यसमा सामान्यतः अदालतले विवादित कानून असंवैधानिक छ भनी अनुमान गर्दछ र विवादित कानून राज्यको वाध्यता हो र यो कारणले गर्दा प्रस्तुत कानून निर्माण गर्नु परेको हो भनी State Compulsion प्रमाणित गर्ने भार राज्यमा रहन्छ । कथंकदाचित् राज्यले सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउन सकेन भने उक्त कानून स्वाभाविक रूपमा असंवैधानिक ठहर भई बदर हुन्छ ।

२.३ कानूनको समान संरक्षण (Equal Protection of Law):

समानताको हक सम्बन्धी अवधारणाको अर्को पक्ष Equal protection of law लाई अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधनको उपज मानिन्छ । प्रकृति, आर्थिक हैसियत, संस्कृति, धर्म आदिका कारण मानिस असमान रहेकाले पूर्ण रूपमा समानताको प्रयोग हुन सम्भव हुँदैन । त्यसर्थ समान परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई समान र असमान परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई असमान व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसैले यसलाई समानताको हकको सकारात्मक पक्ष मानिन्छ । उस्तै परिस्थितिमा रहेका समानहरू बीच असमान व्यवहार गरिनु मात्र होइन असमानहरूका बीच समान व्यवहार गरिनु पनि यो सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको मानिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ Equal Protection of Law/Equality before law एक आपसमा समान हुन् ? वा फरक वा एक आपसको परिपूरक हुन् ? यी दुवैको उद्देश्य के हो ? Equal protection of Law/Equality before law बारेमा पृथक रूपमा माथि चर्चा भइसकेको छ । यसबाट यी दुवैको शब्द बनावट फरक देखिन्छ, साथै दुईको प्रस्तुति र अवधारणा अध्ययन गर्ने क्रममा फरक अर्थ दिने गरी विश्लेषण गरिएको छ । यो विश्लेषणमा संवैधानिक विज्ञानका प्रायजसो विद्वान र विभिन्न देशको संविधान र कानूनको मनसाय एवं अदालतका व्याख्यामा समेत विभिन्नता पाइएको छैन । तर यसको अर्थ के संविधानमा Equality before law मात्र प्रयोग गरिएको देश र Equality before law मात्र प्रयोग भएको देशमा समानता सम्बन्धी हकको परिमाणमा पनि पृथकता देखिन्छ ? अवश्य देखिदैन । अर्थात् Equal protection of law/ Equality before law दुवै उल्लेख हुने देशको संविधान लागु भएका देशका नागरिक र कुनै एक मात्र उल्लेख भएका देशका नागरिकहरूमा समानताको हक उपभोग सम्बन्धमा नत कुनै कमी देखिन्छ नत बढी । यसबाट प्रस्तुति र अर्थ जे देखाइए पनि नतिजा यी अवधारणाको उद्देश्यको प्रकृति र क्षेत्र समान नै देखिन्छ ।

यसलाई वर्णन गर्ने क्रममा नेपाली संवैधानिक कानूनका विद्वान श्री पूर्णमान शाक्यले- Indeed, It will be difficult to imagine any violation of the expression the equal protection of the laws which would not be a violation of the expression equality before law ^७ लेख्नु भएको छ । अर्थात् कानूनको समान संरक्षणको अधिकारको उल्लंघन हुँदा कानूनको अगाडि समानताको अधिकार कुण्ठित हुँदैन भन्न सकिन्छ, कुनै एकको उल्लंघन हुनु भनेको अर्को अवधारणाको पनि उल्लंघन हुनु हो ।

यो दुवै सिद्धान्तमा सारभूत रूपमा कुनै परक छैन भन्ने उल्लेख गर्दै कमन ल प्रणालीको Equality before the law को व्याख्या गर्ने विश्व विख्यात संवैधानिक विधिशास्त्री सर आईभर जेनि आफ्नो Law of the constitution भन्ने पुस्तकमा Equalit before the law means that among equals the law should be equal and should be equally administred, that like should be treated alike लेख्नु भएको छ । जेनिङ्गको उक्त भनाई र अमेरिकी संविधानको Equal Protection of law को व्यवस्था अक्षरसः मिल्न जान्छ । ^८

समानताको हक उल्लंघन हुने गरी कानून बनाउन र व्यवहार गर्न पाइन्न भन्नेमा विवाद रहँदैन बरु यो विवाद कसका लागि कसका विरुद्ध र कसले पालन गर्ने भन्नेमा रहन सक्छ । यस सम्बन्धमा State action theory को अध्ययन गर्नु प्रासंगिक हुन्छ । सन् १२२५ मा घोषित Magna Carta देखि Bill of Rights, फ्रन्सेली क्रान्ति,

Declaration of independence, 1776 हुँदै आधुनिक समयसम्म मानिसलाई प्रदत्त अधिकारहरु राज्यका विरुद्ध हुन । अर्थात् राज्यको कार्य सम्बन्धमा निर्देशित हुन । केहि हक अधिकार व्यक्तिका विरुद्ध भए पनि राज्यद्वारा नै संरक्षण प्रदान हुने हुँदा त्यसलाई पनि यही सिद्धान्त अन्तर्गत नै राख्न सकिन्छ ।

संवैधानिक कानूनमा समानताको सिद्धान्तलाई राज्यपक्षसँग जोडिएको हुन्छ । राज्यद्वारा स्थापित संस्था वा संस्थाका कुनै पनि क्रियाकलापमा नागरिक नागरिक बीच भेदभाव नगरिने व्यवस्था संविधानले अंगीकार गरेको हुन्छ । यो सरकारी स्वेच्छाचारिताको विरुद्ध जनतालाई दिएको एक सशक्त हतियार नै हो ^९ । संवैधानिक घोषणा राज्यका तर्फबाट भएकोले समानताको हक व्यक्तिको विरुद्ध जारी भएको मान्न सकिन्छ । व्यक्तिका लागि राज्य पक्ष विरुद्ध जारी भएको मान्नु पुग्ने हुन्छ ।

^९ Supra note 3

^९ Supra note 2, p 188

२.४ समानताको सन्दर्भमा वर्ग र वर्गीकरण सम्बन्धी अवधारणा :

समानता पूर्ण र निरपेक्ष नभै सापेक्षित विषय हो । यसका सापेक्षता लक्षित वर्गको हैसियत अवस्था, क्षमता आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ । उस्तै परिस्थिति उस्तै हैसियत, क्षमता भएका व्यक्तिहरु एउटा वर्ग हुन । राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा विभेद गर्न पाइन्न भन्ने नागरिकको समानताको हक सम्बन्धमा एवं समानहरुका विचमा समान र असमानहरुका विचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने समान संरक्षणको मान्यता सम्बन्धमा माथि विश्लेषण भइसकेको छ । यस अर्थमा विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग विभाजन गरी त्यस्तो एक वर्ग र अर्को विच असमानता र सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति विच समान रुपमा लागु हुने गरी कानून बनाउन सकिन्छ । यसरी छुट्याउने कार्यलाई वर्गीकरण भनिन्छ ।

मानिसहरुको बनोट र परिस्थिति अनुसार फरक-फरक अवस्थामा रहेका हुने भएकाले तिनीहरुको आवश्यकता पनि फरक-फरक हुन्छन् । त्यस्ता फरक-फरक आवश्यकता पूरा गर्ने सिलसिलामा राज्यले उपयुक्त तवरले मानिसहरुको वर्गीकरण गरी वर्ग सुहाउँदा हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी विभिन्न वर्गलाई फरक-फरक व्यवस्था गरी कानून बनाउने कार्यलाई असमानता मान्न मिल्दैन ^{१०} । तर वर्गीकरण गरिनुको कुनै महत्वपूर्ण आधार हुनुपर्छ र वर्गीकरणको आधार तथा गर्न खोजिएको उद्देश्यका विचमा सार्थक सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ । फरक वा असमान व्यवहार हुनु आफैमा समानताको हकको उल्लंघनको द्योतक होइन, तर वर्गीकरण वा छनोट अनुचित वा स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन ^{११} ।

२.४.१ वर्गीकरण सैद्धान्तिक शर्तहरु:

समानताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यको लागि उचित वर्गीकरण गर्ने कार्य न सहज छ न त असिमित । जे भए पनि वर्गीकरण गर्नु पूर्व यस्तो वर्गीकरण स्वेच्छाचारिता सहित र सारभूत तत्व रहित नहोस भन्ने सजगता राख्नु पर्दछ । सार्थक उचित वर्गीकरण गर्न सक्ने विधायिकी अधिकार न्यायपालिकाको न्यायिक जाँचको क्षेत्रभित्र पनि पर्नु पर्दछ ।

क) विवेकपरक भिन्नता (Intelligible Differentia)

पृथक व्यवहार गर्न छुट्याईएका व्यक्तिहरुको वर्ग अरु व्यक्तिहरु भन्दा अलग भएको स्पष्ट देखिनु पर्छ । यस्तो पृथकता विवेक सम्मत हुनुपर्दछ । कहिल्यै कृत्रिम अस्पष्ट र स्वेच्छाचारीपूर्वक हुनुहुन्न ^{१२} । वर्गीकरणको अर्थ प्रणालीगत सम्बन्ध भएका वर्गहरुलाई छुट्याउनु (Segregation) भएकोले यो स्वेच्छाचारि रुपमा जबरजस्ती एउटै बनाइएको (Herding) नभई वर्ग आम चरित्र र विशेषतले भरिपूर्ण हुनुपर्छ । अर्थात् विभेद गरिने बाहेकका बाँकी अन्य वर्ग वास्तवमै भिन्न देखिने गरी सारभूत भिन्नता (Substantial Distinction) मा आधारित हुनु

पर्दछ । साथै यो सार्वजनिक हित र औचित्यको दृष्टिले समेत उपुक्त हुनुपर्दछ ^{१३} । यस्तो वर्गीकरण वर्तमान परिस्थितिमा मात्र आधारित भएको पनि हुनुहुन्न ।

१. सुरेन्द्र भण्डारी, संवैधानिक कानून, पैरवी प्रकाशन २०५४ पृ. २१९

१०. M.P. Jain Indian constitutional law, vol 1m 5th ed. 2003, Wadhwa Nagpur, P 1000

११. Lbid p 1002

१२. Supra note 2, p.193

१३. Dr.Ram Krishna Timilshena, "Right To Equality and Equal Protection of Law: Phylosophy, Meaning and its Extent", Annual Survey of Neplease Law, 2003, Nepal Bar Council, p.105

वर्गीकरण एक वर्गीकरणमा परेको मानिसहरु र अर्को वर्गीकरणमा परेको मानिसहरुको बीचमा पृथक्ता हुनसक्छ केवल त्यो वर्गीकरण सम्झन बुझ्न सकिने र औचित्यपूर्ण हुनु पर्छ ^{१४} । यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरुले तर्कसंगत रुपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (Arbitrality) गरिएको भन्नु पर्ने हुन्छ ^{१५} । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिम मोही पछि मोहियानी एक प्राप्त हुने उत्तराधिकारीहरुमा छोरी र बुहारीलाई नराखी विभेद गरेको कार्य कानूनको उद्देश्य र नितिसँग युक्तिसंगत (Ratioonal) सम्बन्ध रहेको भन्ने बोधगम्य आधार भएकोले संविधानको धारा ११ को समानताको हक विपरित भई बाझिएको अवस्था नदेखिएकोले स्वतः निस्कृय भइसकेको सत्र मिलेन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ^{१६} । विशेष व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि गरिने वर्गीकरण हेर्दा स्पष्ट र सामान्य समझ भएका व्यक्तिले पनि विवेक सम्मत छ भनी सन्तुष्ट हुन सक्ने प्रकृतिको हुनु पर्दछ ।

ख) उद्देश्यसँग सम्बन्ध (Rational Nexus with the objective of the Act)

सारभूत र वास्तवविक समानता उपलब्ध गराउन राज्यले विभेदकारी कानून बनाउन रोक लागेको मानिदैन । यस्तो विभेदकारी कानून ल्याउनु पछाडि निश्चित उद्देश्य, जुन सरकारको निश्चित नीति कार्यान्वयन गर्न लिएको हुन्छ, अलग कुरा हुन् ।

कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यो वर्गीकरण कुनै विवेकपरक (Rational) सम्बन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरुको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने कारणले मात्र त्यसलाई समानताको हकको प्रतिकूल सम्झन मिल्दैन ^{१७} ।

कानूनको समान संरक्षणले निरपेक्ष समानताको अवस्थाको कल्पना नगरी समानता भन्ने कुरा समानहरुको बीचमा मात्र लागू हुने, असमानहरु बीच समानता कायम हुन नसक्ने । अमूल समूहलाई फरक समूह वा वर्ग अन्तर्गत पर्ने भएकोले फरक व्यवहार गरिएको हो भनी राज्यले उचित रुपमा वर्गीकरण गरी सोको औचित्यता पुष्टी गर्नु पर्ने । एकै अवस्था र हैसियत भएकाहरु बीच फरक व्यवहार गर्दा राज्यले अनुचित रुपमा वर्गीकरण गरी असमान स्थिति रहेको भनी दिएका आधारहरु औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने । संविधानमा उल्लेख भएको समानताको हकको प्रयोजनको लागि जहाँनेर दुई भिन्न वर्ग वा समूहका फरक फरक अवस्था र आधार भएको भनी दावी लिइन्छ त्यस्तो फरक व्यवहार गर्दा लिइएको आधारको वर्गीकरणसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध (Rational Nexus) छ छैन भनी हेर्नुपर्ने । समानहरुका बीच समानता कायम हुने भन्ने सन्दर्भमा असमान व्यवहार गर्न परेको कारण पनि औचित्यपूर्ण हुनु पर्ने ^{१८} ।

ग) विधिसम्मत वर्गीकरण (Lawfull Classification):

व्यक्तिहरूका बीचमा विभेद गर्ने गरी बनाएको कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण वैध (Lawfull) पनि हुनुपर्दछ । त्यस्ता वर्गीकरण चाहे विवेकसम्मत (Intelligible Differentia) भएको होस वा माथि उल्लेख भए बमोजिम ऐनको उद्देश्यसँग सम्बन्ध (Nexus) भएको नै किन नहोस, त्यस्तो उद्देश्य वैध छैन भने वर्गीकरण औचित्यपूर्ण मानिदैन । गैर कानूनी कार्यलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन । त्यसरी ऐन बनाई स्वीकार गरिएको वर्गीकरण अनिवार्य रूपमा कानूनका सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने हुनु पर्दछ । साथै कुनै अमुक वर्गलाई त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नबाट रोक्ने अथवा

१४. ने.का.प. २०५६, नि.नं. ६७४९, पृ. ५०४

१५. ने.का.प. २०४९, नि.नं. ४९७, पृष्ठ ७१०

१६. ने.का.प. २०५३ अंक २ नि.नं ६९४०, पृ १०५

१७. ने.का.प. २०४९ नि.नं ४५९७, पृ ७१०

१८. ने.का.प. २०६५ नि.नं ७९५५, पृ ४५२

कुनै अर्को वर्गलाई अनुचित भार बहन गराउने एवं कार्यान्वयनको क्रममा गैर कानूनी दवाव थोपर्ने पनि हुनु हुँदैन । विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग विभाजन गरी एक वर्ग र अर्को वर्ग बीच असमान तर सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति बीच समान रूपमा लागु हुने गरी कानून बनाउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले अनुपयुक्त हुन सक्दैन । परन्तु: त्यस्तो कानून मनासिव, उचित र जायज भएन भने आफै विभेदकारी हुने ।

वर्गीकरण गर्दा एक भन्दा अर्को फरक छ भन्ने कुरा वर्गीकरण गर्ने कानूनले निर्विवाद रूपले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसरी एक भन्दा अर्को फरक हो भन्ने कुरा छुट्याई सके पछि त्यसरी एक भन्दा अर्को फरक छुट्याउन परेको कारणको उद्देश्य अर्थात वर्गीकरण के उद्देश्य प्राप्तीको लागि गरिएको हो, त्यो पनि स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । सो स्थितिलाई संवोधन हुने गरी बनेको कानून भेदभावकारी हुँदैन र यस्तो कानून प्रयोग गर्दा कानूनको एक वर्गलाई एक व्यवहार र अर्को वर्गलाई फरक व्यवहार गरेको जस्तो देखिए पनि त्यस्तो वर्गीकरण Permissible Classification भै भेदभावकारी व्यवहार भएको नमानिने ^{१९} ।

वास्तवमा वर्गीकरणका आधारलाई वस्तुपरक सिद्धान्तको रूपमा वर्णन गर्न र संविधानमा पूर्व शर्तको रूपमा उल्लेख गर्न सम्भव हुँदैन । यो विधायिकाको असल नियतमा भर पर्दछ भने न्यायिक जाँचको क्रममा अदालतको सन्तुष्टि (Subjective satisfaction) नै मुख्य आधारको रूपमा रहन्छ । साथै यो परिस्थितिगत (Case wise) जाँच हुने विषय पनि हो । तर जाँच गर्दा यति कठोर रूपमा लिइनु पनि हुन्न की समाजमा व्याप्त कतिपय समस्याहरू समाधानका लागि उपयुक्त र उचित कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई रोक लगाउन सक्ने हदसम्म पुगोस ।

वर्गीकरणको सिद्धान्त समानताको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रूप प्रदान गर्ने क्रममा अदालतहरूद्वारा विकास गरिएको सहायक नियम भन्ने गरिन्छ । यो सिद्धान्तलाई वढी जोड दिनु, उत्साही हुनु र यसका आधार खोज्ने नाउँमा निरन्तर प्रयासरत् रहनुले संविधान प्रदत्त समानताको हक सम्बन्धी गौरवमय विषयवस्तुमा क्रमिक रूपमा र थाहै नपाई क्षयीकरण आउन सक्छ । वर्गीकरणको सिद्धान्तमा अधिक ध्यान दिँदा समानताको सिद्धान्तलाई वर्गीकरणको सिद्धान्तले प्रतिस्थापन गर्ने, अवाञ्छित नतिजा भोग्न पुग्ने हुन सक्छ, भने आर्कोतर्फ समानताको आदर्श सिद्धान्तलाई मात्र ध्यान दिने हो भने त्यो आदर्शमा मात्र सीमित रही वास्तविक र व्यवहारिक नहुन सक्छ ।

२.५ वर्गीकरणका विविध आधारहरू :

उल्लेख भएदेखि वाहेक व्यवहारिक दृष्टिबाट वर्गीकरणका केही आधारहरू निम्न छन:-

क) भौगोलिक तथा प्रादेशिक आधार-

कठिन भौगोलिक वनावट, राजधानी र शहरी क्षेत्रबाट धेरै टाढा रहेका, यातायातको दृष्टिले धेरै दुर्गम क्षेत्रहरूको विकास र उत्थानको लागि छुट्टै कानून लागू गर्न सकिन्छ, कार्यान्वयन हुन सक्छ । जस्तो:- भूमि सम्बन्धी ऐन छुट्टाछुट्टै जिल्लामा छुट्टाछुट्टै जिल्लामा छुट्टाछुट्टै मितिमा लागू भएको थियो । त्यस्तै कुनै नयाँ ऐन बनाई कर्णाली प्रदेशको विकासको लागि छुट्टै प्रवन्ध हुन सक्छ ।

ख) ऐतिहासिक आधार:-

इतिहासमा कुनै वर्गमाथि अन्यायपूर्ण भएको थियो जसले उक्त वर्ग पछाडि पर्न गएको अवस्था छ भने क्षतिपूर्ति स्वरूप जस्तो: राज्य रजौटा उन्मुलन भए पनि ती राजाहरूलाई विशेष सुविधा दिनु । भारतको सिक्कीमको जनतालाई विशेष व्यवस्था, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापन गरिए वापत निजलाई विशेष सुविधा आदि उदाहरण हुन सक्छ ।

१९. ने.का.प.२०६५ नि.नं ७९५२, पृ ४१२

(ग) व्यक्तिको ब्यक्तित्व अनुरूप-

राजपत्रांकित र अनंकित भनी गरिने भेद, अनुशासन, अदक्षता, भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा कारवाही गर्नु पर्दा न्यायाधीशहरू, सवैधानिक अंगका प्रमुख, उपमुखहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था आदि उदाहरण हुन । विभागमा कार्यरत विमान परिचारक र विमान परिचारिका जस्तो खास वर्गको पदमा कार्यरत कर्मचारीको सम्बन्धमा विनियम ११ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको व्यवस्थालाई सेवा वा अन्य कर्मचारीहरूको उमेरको सम्बन्धमा विनियम ६३ ले गरेको व्यवस्था बाभियो भन्न नमिल्ने ^{२०} । सामान्य नागरिक, प्रहरी, कुटनीतिज्ञ, न्यायाधीशहरूको लागि विशेष व्यवस्था हुन सक्छ ।

(घ) व्यापार व्यवसायको प्रकृतिको आधार-

ठूला, साना व्यवसायको विषय, जनस्वास्थ्य, वातावरण पार्न प्रभाव, मुनाफा आदिको आधारमा वर्गीकरण गरी छुट्टै कर, सुविधा आदि प्रदान वा खोज्न सकिने ।

ङ) समय, मिति अनुसार वर्गीकरण-

जस्तो अमुक मिति भन्दा पहिला जन्मेकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने, ०३४।९।२७ भन्दा पहिलेको घरसार र व्यवहारमा भएको वण्डाले कानूनी मान्यता पाउने ।

नेपालको वर्तमान परिवेशलाई हेर्ने हो भने वर्गीकरणका थप आधारहरू सिर्जना हुँदै रहेको महसुस हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरू तथा दवाव समूहका रूपमा उठाउँदै गएका विभिन्न समूहको भागलाई हेर्ने हो भने अव धर्म, लिंग जात, जाति मात्र नभई गोत्र, काल्पनिक भौगोलिक विभाजन छालाको रंग, भाषा आदिको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता समूहहरूको तर्क उनीहरूको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने विशेष विवेकपरक भन्न चाहीं सकिँदैन । यस समयलाई शंकास्पद वर्गीकरण शीर्षक अन्तर्गत पृथक रूपमा चर्चा गरौं ।

२.६ शंकास्पद वर्गीकरण (Suspect Classification):

समानताको हक सम्बन्धी अवधारणामा चुनौतिको रूपमा रहेको वर्गीकरण सम्बन्धी अवधारणालाई औचित्यको कसी लगाउने क्रममा शंकास्पद वर्गीकरण पनि एउटा मापदण्डको रूपमा विकसित हुँदै आइरहेको पाइन्छ । यो सिद्धान्त विशेष गरी अमेरिकी अदालतको व्यावहारिक उत्पादन हो । खासगरी जात, जाति राष्ट्रिय उत्पत्ति संस्कृतिक समूह, वाह्य समूह तथा धर्म विशेषका आधारमा गरिने वर्गीकरणलाई यस कोटीमा राख्ने गरिन्छ ।

वास्तवमा अमेरिकी संविधानका १४ औं संशोधनको जड नै जातिय भेदभाव हो र समान संरक्षणको यो व्यवस्था स्थानीय सरकारद्वारा कालाहरुका विरुद्ध गरिको भेदभावबाट उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नै ल्याइएको हो । अमेरिकी न्याय प्रणालीका इतिहासमा कालाहरु प्रति राज्यले नै भेदभाव पूर्ण नीति र स्वयं अदालतले सन् १९५४ भन्दा अगाडि गर्ने गरेको व्याख्यालाई लज्जास्पद घृणाको रूपमा मानिन्छ । त्यसैले यद्यपि जातिगत आधारमा गरिएको वर्गीकरणलाई शंकास्पद तवरले मात्र नभै गैरकानूनी नै मानिन्छ । तर उपचारात्मक योजना लागू गर्ने उद्देश्यले जातिगत आधारमा गरिएको विभाजनहरुलाई भने शंकास्पद मानिन्छ र सूक्ष्म न्यायिक जाँच अन्तर्गत राख्ने गरिएको छ । यस्तो जातिगत आधारमा गरिने वर्गीकरणलाई अमेरिकामै प्रचलनमा रहेको **Compelling Governmental Interest Test** को आधारमा न्यायिक जाँच गरिन्छ, जसमा निवेदकतर्फबाट शंका देखाइयो र मौलिक अधिकारमा आघात पुगेको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत भयो भने राज्यपक्षबाट नै त्यस्तो कानून ल्याउनु पछाडि रहेको सरकारको उद्देश्य र हित प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०. केदार विष्ट वि.प.स. समेत, २०५८ सालको रिट नं. ७४ आ. मिति २०५९/९/२, साभार, नरेन्द्र प्रसाद पाठक, नरेन्द्र प्रकाशन खनाल, सवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतका फैसला, भाग २, २०६०, पृ. ५४

भारतीय अवस्था हेर्ने हो भने यो मापदण्ड विवादास्पद देखिन्छ त्यहाँ विधानको धारा-१५(४), १५(४)४२ र ३३७ हरु जातजातिकै आधारमा विशेष सुविधा प्रदान गर्नेगरी व्यवस्थित छ^{२१} । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ उपधारा (१०) मा पिछडिएको जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति लिए पनि यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा शंकास्पद देखिने हेरिएको थियो र आरक्षण नीति खुलेर अपनाइएको थिएन । तर जनआन्दोलन २०६२/०६३ को भावना भन्दै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा-३५ को उपधारा (१०) मा शिक्षा, स्वास्थ्य आवास, खाद्य सम्पन्नता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामानिक रूपले पिछडिएको आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायत सिमान्तकृत समुदाय तथा गरीबको रेखामुनीका मजदुर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति अख्तियार थियो।नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(ज)को उपधारा (७) मा राष्ट्र विकासमा यवा सहभागीता अभिवद्धी गरदै राजनैतिक , आर्थिक, सामाजिक ,र सास्कृतिक, अधिकार हरको पर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जन जसलाई वर्तमान निजामती, प्रहरी, सेना लगायतका पदहरुमा आरक्षण लागू गरिको छ । यस सम्बन्धमा तत्कालिन संविधान लागू रहँदाकै अवस्थामा पनि कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतद्वारा स्वीकारिएको थियो ।

सामान्यतया ऐन स्वयंले कुनै पनि वस्तु मानिस वा समूहको वर्गीकरण गर्नु हुन्छ, मौलिक कुराहरु उल्लेख गरी त्यस्तो ऐन के कस्तो वर्गमा वस्तु तथा मानिसमा लागू हुने भनी सरकार आफैले निर्धारण गर्नेगरी सरकारको स्वविवेकमा छाडिनु पर्छ भन्ने धारणा राखिन्छ । यसको पछाडि सरकार र सरकार संचालन गर्ने राजनैतिक पार्टीहरुको आफ्नै सिद्धान्त र कार्यक्रमहरु हुन्छन् जसलाई निर्वाचन र संसदद्वारा अनुमोदन भएको कार्यक्रमलाई मूर्तता दिन आवश्यक पर्ने समेतको कारण सरकारको स्वविवेकमा यो छोड्नु पर्दछ भन्ने मानिन्छ । तर समानताको सिद्धान्तलाई मूर्तता दिन गरिने वर्गीकरणमा स्वविवेक प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचरिपूर्वक नगरी विवेकसम्मत गर्नु पर्दछ ।

समानता र स्वेच्छाचारिता जन्म जन्मान्तरका शत्रु हुन । एउटै विधिको शासनको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने दोश्रोले लहडी निरंकुश राजतन्त्रको । त्यसैले कुनै पनि कानून वा व्यवहार समाना र वर्गीकरणको प्रसंगमा न्यायीक जाँच हुँदा स्वेच्छाचारी स्वविवेकको कति प्रयोग भएको छ भनी हुन पर्दछ ।

२.७ समानता र समन्यायः^{२२}

समानताको कुरा गर्दा समन्यायको पनि कुरा आउँछ । समानता र समन्यायको विषय मुलमा एउटै भए पनि समानताले परिमाण तथा प्रक्रिया दुवैमा समानता खोज्दछ भने समन्याय मूलतः प्रक्रिया वितरणमा केन्द्रित रहन्छ । जस्तो निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागीता जुटाउने र साधनहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने कुरा समन्यायको प्रश्न हो भने समानता भनेको अन्तसम्म प्राप्त हुने समान स्थिति हो । समानता लक्ष्य हो, समन्याय माध्यम हो । समानता भनेको विना कुनै भेदभाव स्वच्छ तरिकाले गरिने व्यवहार हो ।

समानता कायम गर्ने उपागमहरू मूलतः तिनवटा छन्:-

१) उस्तैलाई उस्तै व्यवहार गर्ने (Sameness Approach)

२) संरक्षणवादी उपागम (Protectionish Approach)

३) सुधारवादी उपागम (Correctionish Approach)

पहिलो उपगम अरस्तु जस्ता दार्शनिकले बनाएको धारणा हो । तत्कालको दास र नागरिकको भेदलाई मध्यनजर राखेर दासहरूबीच उस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ अर्थात असमानहरूबीच असमानताको आधारमा तदनुकुल उस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ र समानहरूबीच समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनी अरस्तुले भनेका थिए । यसले समानताभिन्नको विविधतालाई समेट्नु भन्दा मानिसलाई नै वर्गीकृत गरेकोबाट समाताको सम्बर्द्धन यसबाट हुन सक्दैनथ्यो ।

२१. Tek Tamarakar, "Reservation Policy as an integral Tenet of Substantial Equality: Concept and Modus Operandi" Annual Survey of Nepalese Law, (2003), Nepal Bar Council, p. 235

२२. कल्याण श्रेष्ठ, समानताको सिद्धान्त र न्याय, तालिम पाठ्य सामग्री, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ।

अरस्तुपछि लोककल्याणकारी सिद्धान्त उपयोगमा आएको छ । यस अन्तर्गत मानिसलाई क्षमता भएको वा नभएको भन्ने धारणा क्षमता नभएकाको लागि राज्यले संरक्षण वा सहूलियत दिने दृष्टिकोण बनाइएको पाइन्छ । क्षमताको आधारमा संरक्षणको कुरा गर्दा व्यक्तिले आत्म निर्णय गर्न नपाउने भई अरुको निर्णयाधीन पुग्न जान्छ । अहिले पनि महिलाले राती काम गर्न निषेध गर्‍यो वा विदेशी रोजगारमा जान पति वा बाबको पूर्व स्वीकृत आवश्यक बनायो भने त्यो संरक्षण बादी उपागम हुन्छ । यसलाई समानता व्यक्तिको हकको रूपमा भन्दा पनि अरुको देनको रूपमा लिइन्छ ।

सुधारात्मक उपागम अन्तर्गत व्यक्तिको वास्तविक स्थितिको सापेक्षतामा समानताको सिद्धान्त क्रियाशिल बनाउने कोसिस गरिन्छ । समानताको हक भएपनि त्यसबाट बञ्चित रही रहेको अवस्थामा हकको प्रचलन गराउन मौजुदा स्थितिहरूमा सुधार गर्ने मुख्य अभिष्ट लिएर यो सिद्धान्त प्रयोगमा आएको छ । यसलाई अर्को शब्दमा सारवान समानताको सिद्धान्त भने पनि हुन्छ । यो उपागमको प्रयोग क्यानडा नगरपालिकाबाट भएको देखिन्छ र अहिले विश्व भरीको न्यायपालिकाले परम्परागत तटस्थाताको उपेक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व बोधको हिस्साको रूपमा यो सिद्धान्तको प्रयोगमा बृद्धि आएको छ । अहिले अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका राष्ट्रहरूले यो सिद्धान्तको साहाराबाट धेरै सामाजिक अन्यायहरूलाई निकास दिन सम्भव भएको छ । न्यायपालिकाहरूले आफ्नो रचनात्मक भुमिका मार्फत समाजमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने विधाको रूपमा यसलाई हेरेएको छ ।

समाजमा समानताको हक उपभोग पाउने भएका वर्गभित्र विभिन्न तहका वा समूहका व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूको हैसियतलाई विचार नगरी निरपेक्ष रूपमा सबैलाई बराबर व्यवहार गर्ने भनेका उनीहरू भित्रको असमान परिस्थितिहरूलाई निरन्तरता दिनु भनेको जस्तो हुन्छ । यसबाट समानता कायम गर्नु भन्दा असमानता बढाउने काम हुन्छ, त्यसैले महिला, एवं अल्पसंख्यकलाई सारवान रूपले समाजको हकदार हुन भनि फरक व्यवहार गर्नु जरुरी छ ।

२.८ सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination):

असमानहरुलाई समान बनाउने उद्देश्यले कुनै व्यक्ति वर्ग विशेषलाई दिइने अस्थायी प्रकारको प्राथमिकता वा छुटलाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान र सामान्य कानूनको प्रयोगमा नागरिक माथि धर्म, वर्ण, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा, लिंग वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराका आधारमा भेदभाव नगरिने मान्यता औपचारिक सामानता हो भने आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गको विकास, संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नुलाई सकारात्मक विभेद (Positive discrimination/ Affirmative action) भन्ने बुझिन्छ । सकारात्मक विभेद सम्बन्धी व्यवस्था कानूनको समान संरक्षणका उपज हो ^{२३} ।

सकारात्मक विभेद समाजमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक एवं व्यवसायीक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, सम्प्रदाय वा समूहको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक शैक्षिक एवं व्यवसायिक अवस्था सुधार्न राज्यद्वारा गरिने विशेष व्यवस्था हो । यसलाई यसकारण सकारात्मक विभेद भनिन्छ कि यस विभेदले समाजका कमजोर एवं पछाडि परेका वर्ग, सम्प्रदाय वा समूहको अवस्था सुधार्न सकारात्मक उद्देश्य लिएको हुन्छ र समाजका बहुसंख्यक जनता (People at large) ले यसको उक्त सकारात्मक उद्देश्यलाई इन्कार गर्न सक्तैनन् । सकारात्मक विभेद सारवान समानता कायम गर्ने एक प्रमुख साधन वा माध्यम हो । सारवान समानता साध्य हो भने सकारात्मक विभेद साधन हो । समाजशास्त्रीहरुका अनुसार समाजको हरेक चरणमा पाँच प्रकारले असक्षम व्यक्तिहरु पाइन्छन् । ती (Physical, Mental, Social, Economic र Political disability) हुन् । उनीहरुका अनुसार एउटा समाजले यी पाँच प्रकारले असक्षम व्यक्तिहरुको संरक्षणमा विशेष जोड दिन्छ ।

२३. संविधानसभा, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति विषयगत अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक प्रतिवेदन, २०६६, पृ. १८२

सकारात्मक विभेदले शताब्दियौँदेखि अन्यायमा परेका खास समुदायहरुको क्षतिपूर्तिको दावी गर्दछ ।

यसका अनुसार समाजको प्रारम्भिक चरणबाटै समाजका केहि हुने खानेहरुले समाजका कमजोर वर्ग उपर ज्यादै अन्याय गरी राज्यको मुल्धारबाट पछाडि पार्ने कार्य गरेकाले यसरी अन्याय गर्नेका सन्ततीहरुले आफ्नो पुर्खाले पछाडि पार्ने कार्य गरेकाले यसरी अन्याय गर्नेका सन्ततीहरुले आफ्नो पुर्खाले गरेको अन्याय वापत क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्दछ र त्यो क्षतिपूर्ति नै सकारात्मक विभेद हो ।

सारभूत रुपमा समानताको प्राप्ति विना समानता सम्बन्धी अवधारणा कोरा सिद्धान्त मात्रको र औपचारिकतामा सिमित हुन पुग्दछ । सारभूत समानताको प्राप्तिा लागि समानता सम्बन्धि सिद्धान्तका विभिन्न उप-सिद्धान्तहरुको जन्म भएको पाइन्छ । त्यसमध्ये संरक्षणात्मक विभेद (Protective discrimination), सकारात्मक व्यवहार (Affirmative action), न्यायोचित वर्गीकरण (Reasonable Classification) लाई मुख्य रुपमा लिन सकिने । एउटा वर्ग वा समुदायको समस्या रीत, परम्परा र व्यवहार अर्कोको भन्दा फरक हुने हुँदा ती विविधतालाई समान कानून र समान व्यवहारको निरपेक्ष दृष्टिकोणले संबोधन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि छुट्टै कानूनी प्रवन्ध, कानूनी संरक्षण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ । तर त्यसो गर्दा समानहरुका बीचमा समानतालाई भने जोगाउनु हो । ^{२४}

संवैधानिक विधिशास्त्रमा सकारात्मक विभेदको उत्पत्ति र कार्यान्वयनको आवश्यकता राज्यलाई लोक कल्याणकारी चासो (The need to introduce and implement the concept of positive discrimination in the constitutional jurisprudence is guided by the concern of the state to turn itself into a welfare state and achieve the lofty objective of social justice) लाई भनिन्छ । Affirmative action शब्द सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रयोग भएको थियो । सन् १९६१ को मार्चमा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले कार्यकारी आदेश नं. ०९२५ जारी गर्दा यस शब्दको प्रयोग गरेका थिए । यस आदेशले President's Committee on Equal Employment Opportunity गठन भएको थियो । उक्त आदेशमा भनिएको थियो कि "The contractor will take affirmative action to ensure that applicants are employed, and that employees are treated during

employment, without egard to their race, ceed, colour, or national origin" यसरी उत्पत्ति भएको सकारात्मक विभेदले ४७ वर्ष पार गर्दा नगदै विश्वका प्राय सबै मुलुकहरुमा जरा गाडिरहेको छ ।

समानताको अवधारणाको पुरक अवधारणा मानिने सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई जनाउन विभिन्न शब्दहरु प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । जस्तो:-

1. Postive discrimination action	2. Protective discrimination
3. Progressive discrimination	4. Affermative discrimination
5. Affermative action	6. Substactial equality
7. Preferentive treatment	8. Reverse discrimination
9. Social Justice	10. Compensatory discrimination
11. Preferntial Justice	12. Compensatory action
13. Preferential theory	14. Compensatory state acion
15. Special Provision	16. Consequential equality

२४. ने.का.प. २०६५, नि.नं. ७९६१, पृ. ५४५

२.९ सकारात्मक विभेदको सैद्धान्तिक एवं वैधानिक आधार:

सकारात्मक विभेद समान अवसरमा मात्र सिमित नभै परिमाणमा नै समानता ल्याउने सारभूत समानताको एउटा सार्थक उपाय हो । समानता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरुलाई जति मजबुत र स्पष्ट तुल्याए पनि हरेक देशमा कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै जोड दिएको पाईन्छ । मानवीय मुल्य र मान्यताले गर्दा मात्र नभै ति पिछडिएका वर्ग र समूहलाई अग्रगति लिएका वर्ग समान नबनाउँदा विकासको गति र मानवीय प्रगति नै निरर्थक हुने हुँदा समेत त्यस्तो पिछडिएको वर्गलाई विशेष सुविधा, छुट वा अवसर दिई अग्रगतिमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

जनावरलाई उदाहरणको रुपमा लिने हो भने जनावरहरुको विचमा भेदभाव गरिनु हुँदैन भनेर कुनै चिडियाखानाले मृग र सिंहलाई एउटै थालमा मासु हालेर खान दियो भने नतिजा कस्तो निस्कन्छ । पहिले मासु खान्छ र मौका परे मृगलाई नै खाइदिन्छ । तर मृग यसैगरी कानूनले धनी र गरीब गर्नलाई समान रुपमा हेर्दछ । यस क्रममा कुनै कानूनले गरीबको हकमा विशेष व्यवस्था नगरी, माग्ने कार्यमा पूर्ण रोक लगाउँछ, फ्याकिएको र बासी खाना खान पूर्ण निषेध गर्दछ, पुलमुनी तथा सडकको पेट्टीमा सुत्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरी सजायको व्यवस्था भयो भने यस्तो समानता हास्यास्पद मात्र हुन पुग्दछ ।

सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको पछाडि रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दार्शनिक वर्ग भनेको पिछडिए, राष्ट्रिय जीवनको मुलधारामा आउन नसकेको वर्गलाई विगतमा गरिएको भेदभावपूर्ण नितिका कारण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा उचित अवसर प्राप्त गर्न नपाएका कारण पछि परेका हुन् । तसर्थ उक्त विगतको भेदभावपूर्ण व्यवहारको क्षतिपूर्ति स्वरुप वर्तमानमा निजहरुलाई विशेष सुविधा, छुट वा अवसर वा उपलब्ध गराइनु पर्छ भन्ने रहेको छ । तसर्थ यस अवधारणालाई compensatory discrimination अथवा compwnsaroty state action पनि भनिन्छ ।

वेलायतमा positive discrimination शब्दलाई सेवा तालिम (Job training, extra Schooling, Subsidized housing) खाद्य कार्यक्रम पिछडिएका वर्गलाई हितको लागि व्यवस्था गरियो, लाई जनाउन प्रयोग

गरिन्थ्यो । भारतमा स्वतन्त्रता स्थापित हुनु अघिनै यस सम्बन्धी अवधारणा शुरु भैसकेको पाइन्छ । यहाँका मसुरी राज्यले सर्वप्रथम आरक्षण व्यवस्था अवलम्बन गरेको थियो, मने कोल्हापुर मद्राय जस्ता राज्य समेत जातियतामा आधारित आरक्षण पद्धती अवलम्बन गरेका थिए ।^{२५} वर्तमानमा पनि सकारात्मक विभेद सम्बन्धी अभ्यास भारतमै उच्चतम् विन्दु र प्रभावकारी रुपमा लागु गरिएको छ ।

२.१० सकारात्मक विभेदको आवश्यकता र उद्देश्य:

सकारात्मक विभेद जसलाई (Reverse Discrimination) पनि भनिन्छ, को मुख्य उद्देश्य पिछडिएका र कमजोर वर्गलाई विगतमा गरिएको विभेदमुलक व्यवहारका लागि क्षतिपूर्तिस्वरुप वर्तमानमा उनीहरुको विकास र उन्नतिको लागि विशेष कदम चाल्नु हो, भने यसको विपरित वर्ग जसलाई यस्तो विभेदले बाहेक गरेको हुन्छ, लाई दायित्वशील (Liable for past discriminatory environment) बनाउनु तथा विगतको गलतिको संशोधन हुने अवसर प्रदान गर्नु पनि हो । संक्षेपमा सकारात्मक विभेदको आवश्यकतालाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

- समतामूलक समाजको स्थापनाको लागि यो आवश्यक हुन्छ ।
- विविधताका बीच एकता कायम गर्न आवश्यक छ । पिछडिएका र कमजोर वर्गका आत्मसम्मान र आत्मसम्मान र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दै समान मानवीय मूल्य अनुभूत गराउन यो सफल हुन्छ । अल्पसंख्यकहरुको राज्यप्रतिव अपनत्वको भाव अभिवृद्धि गर्न यो बल पुऱ्याउँदछ ।

२५. विन्दा हाडा, “सामाजिक समावेशीकरण” कामाद, अंक २, असोज प्रकाशन, व्यवस्थापन र विकास केन्द्र काठमाण्डौ २०६१

- शोषणरहित समाजको सपना साकार पार्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
- योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई कायम गर्दै विविधताको महत्व (Diversity as a value) को सिद्धान्तले पनि प्रश्रय पाउँछ जसले, बहु आयामिक संगठन निर्माणमा सहयोग पुऱ्याउँछ ।^{२६}
- विविधताका बीच आपसी सहयोग, सहमति र सौहाद्रत बढाउँछ यस्तो एकताले शान्ति र सुरक्षा कायम हुन्छ जसले दिगो विकासलाई सहयोग पुऱ्याउँछ ।^{२७}
- सकारात्मक विभेदका नितिहरुको पक्षमा दिइने सबै भन्दा प्रमुख तर्क हो “विगतका गल्तीलाई सच्याउनु” (Correction of historical wrongs)^{२८}

२.११ सकारात्मक विभेदका विपक्षका तर्कहरु:

माथिका विवरण र विश्लेषणबाट यसको पक्षमा रहेका तर्कहरु अनुभूत हुन सक्ने नै हुँदा पुनः यसमा रहेका मतहरु उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिदैन । तर यसको विपक्षमा रहेका मतहरुलाई संक्षेपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

- 1= यो समानताको उच्च आर्दश विपरीतको अवधारणा हो ।
- 2= प्रतिस्पर्धा मूलक खुल्ला नीति Lessee's faire को विरुद्ध छ ।
- 3= प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्दैन ।
- 4= सक्षम र सुयोग्य वर्गमा हितमा प्रतिकुल असर नै यसको ठूलो नकारात्मक प्रक्ष हो ।^{२९}
- 5= वर्गीकरण गर्ने नाउँमा संकुचित हुँदै राज्यलाई पुनः स्वेच्छाचारी पक्षपातपूर्ण स्वविवेक प्रयोग उन्मुख गराउँछ ।
- 6= सक्षम, प्रतिस्पर्धा र सवल वर्गलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर न्यूनीकृत गर्छ ।
- 7= राज्यलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने निरन्तरता प्रदान गर्दछ ।
- 8= विशेष व्यवहार गर्ने निरन्तरता प्रदान गर्दछ ।

- 9= कमजोर वर्गको मानसिकता भन्ने कमजोर हुन गै आत्म विश्वासमा कमी ल्याउँछ । यो नितिले कमजोर र
10= पिछडिएका वर्ग, व्यक्तिहरु प्राकृतिक रुपमै आत्मक्षमताका हुन्छन् भन्ने भावनालाई उर्जा प्रदान गर्दछ ।
सकारात्मक विभेदको नीति लागू गरिएको क्षेत्रको सेवा, सञ्चालन, उत्पादन स्तरमा ह्रास ल्याउँछ ।

२६. Ibid, p. 66

२७. Id

२८. Id, p.65

२९. Id

२.१२ सकारात्मक विभेदका उपायहरु :

(क) आरक्षण(Reservation)

सकारात्मक विभेद गर्ने नीतिलाई व्यवहारिक स्वरूप प्रदान गर्ने विभिन्न उपायहरु मध्ये आरक्षण प्रमुख, धेरै देशहरुमा प्रयोग गरिएको, उपयोगी, परिमाणमुखी एवं प्रभावकारी उपाय हो । पिछडिएका र कमजोर वर्गको प्रगति, उन्नति र विकासको लागि आवश्यक भनी यसको चर्चा गरिए जस्तै यस सम्बन्धमा विवाद पनि त्यतिकै पाइन्छन् । त्यसैले नेपाल लगायत कतिपय देशमा यो चुनावको निमित्त प्रचारको क्रममा मात्र सिमित छ ।

कतैकतै आरक्षण र सकारात्मक विभेदलाई एउटै अर्थमा लिने गरिएको पनि पाइन्छ । आरक्षण संरक्षणवादी अवधारणा हो आरक्षणमा निश्चित सीट संख्यामा वर्ग विशेषले मात्र स्थान पाउने गरेको हुन्छ । तसर्थ आरक्षण सकारात्मक विभेदभन्दा निकै अगाडि बढेर विशेष रुपमा दिइने संरक्षणको सुनिश्चितता हो ।^{३०} यो प्राथमिकता प्राप्त न्याय हो । आरक्षणको नीति लामो समयसम्म शोषण, पीडित, दलित, गरिबी अभावको स्थितिमा राखिएकाहरुलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति हो ।

आरक्षण सम्बन्धी सैदान्तिक अवधारणा विकासक्रम, यसको आवश्यकता, पक्ष विपक्षमा रहेका मत जस्ता सैदान्तिक पक्षहरु सकारात्मक विभेदसँग सम्बन्धित सैदान्तिक पक्ष जस्तै हुन् । आरक्षणकै सन्दर्भमा विशिष्ट रुपमा चर्चायोग्य केहि सबषयहरु निम्न छन्:-

आरक्षणको मात्र

समाजमा रहेका अल्पसंख्यक, कमजोर एवं पिछडिएका व्यक्ति एवं वर्गको आरक्षण सशक्तिकरण र विकासका लागि आरक्षण प्रदान गर्न सकिने कुरालाई प्राय सबैले स्वीकार गरेको पाइन्छ । तर यसरी प्रदान गरिने आरक्षणको मात्रा कति हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा भने सबैको आ-आफ्नो मत हुन सक्दछ । यस सम्बन्धमा हेर्दा Mr. Balaji V. State of Mysore को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । उक्त मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि यसरी प्रदान गरिने आरक्षणको सीट विवेकपूर्ण सीमामा रहेर निर्धारण गरिनुपर्दछ र यसमा लागू वर्ष भरिका रिक्त पदहरु मध्येबाट ५०% नबढ्ने गरी निर्धारण गरिनुपर्दछ र ५०% भन्दा कम कति प्रतिशत नबढ्ने गरी निर्धारण गरिनु पर्दछ र ५०% भन्दा कम कति प्रतिशत निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा आरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने व्यक्ति एवं वर्गको जनसंख्या, भेदभावको गाम्भीर्यता र उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक र सांस्कृतिक पछिनेपन एवं अवस्था जस्ता कुराहरुमा भर पर्न सक्दछ । आरक्षणको मात्रा निर्धारण गर्दा एउटा कुरा सधैं विचार गरिनु पर्दछ कि आरक्षण एउटा कानूनी अधिकार हो र यसले संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकको समानताको मौलिकहकलाई निस्तेज पार्न सक्दैन । सबैका लागि प्रदान गरिएको मौलिक हक निष्क्रिय हुने गरी केहिका लागि प्रदान गरिने आरक्षणको कानूनी अधिकारको व्यवस्था हुन सक्दैन ।

आरक्षणको सिमाहरु-

आरक्षणको सिमाहरु सम्बन्धमा हेर्दा यो सामान्यतः राज्य वा सरकारद्वारा कानून वा कार्यक्रममार्फत समाजका सीमान्तकृत वर्गका लागि गरिएको क्षणिक व्यवस्था हो । यसर्थ यो सामान्यतः सरकारी क्षेत्रमा मात्र लागू भएको पाइन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रमा यसलाई बाध्यकारी रूपमा लागू गर्न सकिदैन । सरकारी निकायहरुमा हुने शुरु भर्ना र सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनका लागि लिइने भर्नामा आरक्षणको व्यवस्था गरिने गएको पाइन्छ । सरकारी निकायहरुमा नियमित रूपमा हुने बढुवा प्रक्रियामा सामान्यतः आरक्षण प्रदान गरिदैन । तर यसको मतलब गैर सरकारी क्षेत्र एवं बढुवामा आरक्षण प्रदान गर्न नसकिने भन्ने चाँहीं होइन ।

समय सीमा-

सिद्धान्तः आरक्षण सवलीकरण गर्ने एउटा प्रक्रिया हो । यो निरपेक्षन रूपमा साधैको लागि उपलब्ध हुने नभै सीमान्तमा परेको व्यक्ति वा वर्गको स्थिति सामान्य स्तरका वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नहुनेजसम्मको लागि हो । किनभने सारभूत सिद्धान्त त समानतानै हो । राज्यले अनावश्यक विभेद गर्न मिल्दैन र आरक्षणको समय सीमा सीमान्तमा परेको वर्गको आवश्यकता, पिछ्छौटोपनको गम्भीरता आदिलार्थ मध्यनजर गरी निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

आरक्षण सक्षम र सबल समुदायको लागि आवश्यक हुदैन । निर्वल, कमजोर र पिछ्छिडिएको समुदायको लागि पनि गर्वको विषय होइन, बाध्यतको विषय हो । तसर्थ यस्तो वर्गको जीवनस्तरमा सुधार भएपछि उनीहरु आफैले आरक्षणको सुविधा नलिन र प्रतिस्पर्धात्मक बल दिन शुरु गर्दछ ।

आरक्षण व्यवस्था कुनै लक्षित वर्गलाई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गरी राष्ट्र सबैको साझा घर हो र राष्ट्रले सबैको समान सम्मान र संरक्षण गर्दछ भन्ने भावना जागृत गराउने एक माध्यम भएकोले यो सदाका लागि नभै निश्चित र छोटो अवधिका लागि मात्र लागू गरिएको अल्पकालिन व्यवस्था हो । त्यसर्थ यसले लिएको लक्ष्य पूरा हुनासाथ यसलाई अन्त गरिन्छ । आरक्षण एक अल्पकालिन व्यवस्था भए तापनि यसलाई एक पटक लागू गरेवापत यसको अन्त गर्न व्यवहारिक रूपमा निकै कठिन हुने देखिन्छ । भारतमा केहि समयसम्मका लागि भनी लागू गरिएको यो व्यवस्था संविधान लागू भएको ५५ वर्ष भन्दा बढी अवधि हुँदा समेत हटाउन सकिएको छैन । यसैका कारण भारतमा हजारौंको जुलुस, बन्द र हडताल हुने गरेको र केहि व्यक्तिले आत्मदाह समेत गरेका कुरा प्रकाशमा आएको छ ।

आरक्षणको क्षेत्र

प्रत्येक देशले छुट्टाछुट्टै क्षेत्रमा आरक्षण दिने गरेका छन् । जस्तोः पाकिस्तानमा राजनीतिक क्षेत्र, बंगलादेशमा- प्रशासनिक क्षेत्र, भारतमा- राजनीति, प्रशासन र शैक्षिक क्षेत्रमा आरक्षण प्रदान गर्ने गरेका छन् भने मलेसियामा- शिक्षा, रोजगारी, व्यापारिक इजाजतपत्र र जग्गा जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्ने कुरामा समेत भूमिपुत्र मलेसियालीहरुलाई आरक्षण प्रदत्त छ ।

आरक्षण सम्बन्धी नियम-

आरक्षण सम्बन्धी मुख्यतः दुई नियमहरु पाइन्छन् । ^{३१}

क) Carry-Forward Rule: यस अन्तर्गत कुनै एक वर्ष कुनै जातजाति, व्यक्ति, वर्ग सम्प्रदाय वा समूहका लागि आरक्षित सीटमा सो वर्ष ती जातजाति, व्यक्ति, वर्ग सम्प्रदाय वा समूहका योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको अभावले गर्दा पदपूर्ति हुन नसकेमा ती छुट्याइएका आरक्षित पदहरु स्वतः तिनै जातजाति व्यक्ति समुदाय वा समूहका व्यक्तिहरुका लागि अर्को वर्षको आरक्षित सीटमा थप हुन जान्छ । यस अन्तर्गत एकका वर्गका लागि छुट्याइएको पदमा अर्को व्यक्ति भर्ना हुन सक्दैन ।

ख) Non carry-forward rule: यो carry-forward rule को विपरीत छ । यस अन्तर्गत कुनै एक वर्ष कुनै जातजाति, व्यक्ति वर्ग समुदाय वा समूहका योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको अभावले गर्दा सो वर्ष पदपूर्ति हुन

नसकेमा अर्को बर्ष पुनः तिनैका लागि स्वतः सदैव । यसरी रिक्त पदहरु सम्पूर्ण रिक्त पदमा समावेश भै पुनः पदपूर्ति प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ ।

आ) सशक्तिकरण

लक्षित वर्गको समस्या पहिचान गरी उनीहरुको उन्नति र विकासको लागि उपयोगी निःशुल्क तालिम, विशेष, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, अध्ययन भ्रमण आदिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

केहि बर्ष महिला मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको अअधिकृत तहमा प्रतिस्पर्धाका लागि सञ्चालन गरेको प्रशिक्षण राम्रो उदाहरण हो ।

३०. Id, p 64

इ) जनचेतना

लक्षित वर्ग शोषित, पीडित हुनुका साथै समाका अनय वर्ग भन्दा पछि पर्नाको कारण बारेमा जानकारी दिँदै यसबाट मुक्त हुने उपाय बोध गराउने, यसका लागि विशेष चेतना मूलक शैक्षिक कार्यक्रम, भेला गोष्ठी, प्रवचन आदि जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ ।

ई) शैक्षिक उत्प्रेरणा

औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा र अध्ययनका लागि उत्प्रेरित गर्ने, शैक्षिक संख्याहरुमा भर्ना, प्रवेश आदिमा, विना प्रवेश परीक्षा अध्ययन गर्न व्यवस्था, शैक्षिक, परीक्षा शुल्क आदिमा सहूलियत, छुट आदिको व्यवस्था, पाठ्य सामग्रीको निःशुल्क वा सहूलियत सहितको उपलब्धता, विशेष पुरस्कारको व्यवस्था आदि गर्न सकिने छ ।

उ) सुविधा, छुट

जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने घर, जग्गा आदिको राज्यतर्फबाट व्यवस्था सहूलियतपूर्ण उपलब्धता, अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा विशेष राहत कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा परीक्षकालमा सहूलियतको व्यवस्था आदि गर्न सकिने छ ।

ऊ) वकालत

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिले पिछ्छडिएका वर्ग, महिला, बालक, वृद्ध आपाङ्ग आदि जस्ता सकारात्मक विभेद गर्न सकिने भनी पहिचान गरिएका वर्गको उन्नति, उत्थान र विकासको लागि विभिन्न सार्वजनिक मञ्च, सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रमा उनीहरुको तर्फबाट आवज उठाउने, वकालत गर्ने आदि कार्य यस शीर्षकमा राख्न सकिन्छ ।

ए) कानूनी सहायता

अण्डा अदालतमा आफू उपर वा आफ्नो तर्फबाट दायर रहेका वा दायर गर्नुपर्ने मुद्दामा आवश्यक कानूनी सल्लाह, सहायता, प्रतिनितित्व समेत गर्नेगरी विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

३१. Supra note 6 p 102

परिच्छेद- ३

समानताको हक र सकारात्मक विभेद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूको आचरण तथा पारस्परिक सम्बन्धलाई संचालित गर्ने नियम तथा अन्य स्रोतहरूको सम्बन्धलाई संचालित गर्ने नियम तथा न्याय स्रोतहरूको समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून भन्दछन्।^{३२} अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, महासमन्धि, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र आदि पर्दछन्। यसै सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भएको यस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था र विश्वका केही ठूला र प्रजातान्त्रिक देशमा भएको यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र त्यसको प्रयोग बारेमा यहाँ संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ।

३.१ संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र:

आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा मानवीय प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा, तथा जाति, लिंग, भाषा वा धर्ममा भेदभाव नराखी सबैका लागि मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रताहरू प्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित विकसित गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा तथा जाति, लिंग, भाषा, वा धर्मको भेदभाव विना सबैलाई मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको उपलब्ध गराउनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्य महासभाले गर्दछ।^{३४}

जाति, लिंग, भाषा वा धर्मको भेदभाव विना सबैका लागि मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरूको विश्वव्यापी सम्मान तथा पालना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रोत्साहित गर्दछ।^{३५}

३.२ मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा-पत्र, १९४८

सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन्। उनीहरू विवेक र अन्तरस्कराले युक्त भएका हुन्छन्। उनीहरूले मातृत्वको भावना लिएर एक अर्काप्रति व्यवहार गर्नुपर्दछ।^{३६}

जाती, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव विना प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको अधिकार हुनेछ। साथै कुनै पनि व्यक्ति रहेका मुलुक वा इलाका स्वतन्त्र, न्याय, स्वशासन रहित वा सार्वभौमसत्ताको अन्य कुनै पनि सीमाको अधिनमा रहेको जे भएतापनि त्यस्तो मुलुक वा इलाकाको राजनीतिक, क्षेत्राधिकारगत वा अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन।^{३७}

३२. डा. गोपाल शर्मा, संक्षिप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानून, छैटौँ पेरवी प्रकाशन, २०६६, पृ. १५

३३. संयुक्त राष्ट्र संघको वडा पत्र, १९४५ धारा १(३)

३४. Ibid धारा १३

३५. Id धारा ५५

३६. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, धारा १

३७. Id धारा २

सबै व्यक्तिहरु कानूनको दृष्टिमा समान र कुनै पनि भेदभाव विना कानूनको समान संरक्षणको हकदार छन् । सबै व्यक्तिहरुलाई यस घोषणापत्रको उलंघन गरी गरिएको कुनै संरक्षणका हकदार छन् । सबै व्यक्तिहरुलाई यस घोषणापत्रको उलंघन गरी गरिएको कुनै पनि प्रकारको भेदभाव विरुद्ध वा त्यस्तो भेदभावको दुरुत्साहन विरुद्ध समान संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।^{३८}

प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न, कपडा, आवास र औषधोपचारको सुविधा र आवश्यक सामाजिक सेवाहरु ल्याउन पर्याप्त जीवनस्तर अधिकार तथा बेरोजगारी, विरामी, अशक्तता, विधवा, बुढेसकाल वा आफ्नो काबु बाहिरका परिस्थितिहरुमा जीवीकोपार्जनका उपायका अभावमा सुरक्षा पाउने अधिकार छ । आमा र शिशुहरुलाई विशेष स्याहार र सहायता पाउने अधिकार छ । विवाह भई वा नभई जन्मेका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुले समान सामाजिक संरक्षण पाउने छन् ।^{३९}

३.३ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९७१

पुरुष र महिलाबीचको समानताको सिद्धान्तलाई आफ्नो राष्ट्रिय संविधान वा अन्य उपयुक्त कानूनमा आफै समावेश गरी वास्तविक नसकिएको भए यस सिद्धान्तलाई त्यस्तो संविधान वा प्राप्त सुनिश्चित गर्ने काम गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्र कबुल गर्दछन् ।^{४०}

पुरुष र महिलाबीचको वास्तविक समानतालाई तीव्र पार्ने उद्देश्यले पक्ष राष्ट्रहरुबाट ग्रहण गरिएका अस्थायी विशेष उपायहरुलाई भेदभाव मानिने छैन । तर परिमाणस्वरूप यस्ता उपायहरुको कुनै पनि हालतमा असमान वा पृथक मापदण्डहरुलाई कायमै रहन दिनु हुँदैन । अवसर र व्यवहारको समानताको उद्देश्य हासिल भएपछि यी उपायहरुलाई निरन्तरता दिईने छैन ।^{४१}

पक्ष राष्ट्रहरुले पुरुष सरह र कुनै भेदभाव विना अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको कार्यमा सहभागी हुने अवसर महिलाको लागि सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नेछन् ।^{४२}

पक्ष राष्ट्रहरुले महिलाहरुलाई कानूनका दृष्टिमा पुरुष सरहको समानता प्रदान गरी सो क्षमताको उपयोग गर्न समान अवसर प्रदान गर्नेछन् । उनीहरुले खासगरी महिलाहरुलाई अधिकार गर्न र सम्पत्तिको संचालन गर्न पाउने समान अधिकार प्रदान गर्नुका साथै अदालत तथा न्यायाधिकरणका कार्यविधिहरुमा सबै तहहरुमा महिलाहरुलाई समान रूपले व्यवहार गर्नेछन् ।^{४३}

३८. Id धारा ७

३९. Id धारा २५.४०. महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९, धारा २

४०. महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९, धारा २

४१. Ibid धारा ४

४२. Id धारा ८

४३. Id धारा १५

३.४ महिलाहरूको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९५२

यस महासन्धिको प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै रूपमा भएपनि स्वतन्त्र रूपमा चुनिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा राज्य संचालनमा भाग लिन पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई मान्यता दिँदै देशको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको प्रत्याभूति दिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषडापत्रमा उल्लेखित राजनीतिक अधिकारको उपभोग र अभ्यासमा महिला र पुरुषको समान हैसियत कायम गर्ने रहेको छ ।

महिलाहरूले कुनै पनि भेदभाव विना पुरुष सरह सबै निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउनेछन् ।^{४४} महिलाहरू कुनै पनि भेदभाव विना पुरुष सरह राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक रूपले निर्वाचन हुने सबै निकायहरूको निर्वाचनको लागि योग्य हुनेछन् ।^{४५}

महिलाहरू कुनै पनि भेदभाव विना पुरुष सरह राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक पद धारण गर्न र सम्पूर्ण सार्वजनिक काम गर्न पाउनेछन् ।^{४६}

३.५ नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६

प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरू आफ्ना इलाका तथा क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म, वा अन्य हैसियतका आधारमा कुनैपनि प्रकारको भेदभाव विना प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकृत अधिकारहरूको सम्मान र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् ।^{४७}

सबै व्यक्तिहरू अदालत तथा न्यायाधिकरणको अगाडि समान हुनेछन् ।^{४८} सबै व्यक्तिहरू कानूनको दृष्टिले समान छन् र कुनै पनि भेदभाव विना कानूनको समान संरक्षणका हकदार छन् । सम्बन्धमा कानूनले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गर्ने र सबै व्यक्तिहरूलाई जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव विरुद्ध समान तथा प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति दिईनेछ ।^{४९} भन्ने व्यवस्था प्रतिज्ञापत्रले गरेको छ ।

^{४४}. महिलाको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९५२, धारा १

^{४५}. Ibid धारा ३

^{४६}. Id धारा ३

^{४७}. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, धारा २

^{४८}. Ibid धारा १४(१)

^{४९}. Id धारा २६

३.६ वाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९

यस महासन्धीको उद्देश्य वालवालिकाहरुमा शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वता रहने हुनाले तिनीहरुलाई विशेष सुरक्षा र हेरचाहको आवश्यकता पर्ने भएकोले उनीहरुलाई विशेष कानूनी संरक्षण दिने रहेको छ ।

सार्वजनिक वा निजी कल्याणकारी संस्थाहरु, अदालतहरु प्रशासनिक अधिकारीहरु वा विधायिकी निकायहरु जोसुकैबाट गरिने वालवालिकासँग सम्बन्धित सबै कार्यहरुमा वालवालिकाको सर्वोत्तम हित नै प्राथमिक विचारको कुरा हुने ।^{५०}

पक्ष राष्ट्रहरुले वालवालिकाको हितका कुनै पनि पक्षलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका शोषणबाट वालवालिकालाई संरक्षण गर्ने छन् ।^{५१} कुनै पनि वालवालिकालाई यातना दिइने वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन । नत अठार वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुद्वारा गरिएका कसुरहरुका लागि मृत्युदण्ड सजाय वा रिहाइ पाउने सम्भावना बिनाको आजीवन कारावासको सजाय नै दिइनेछ । गैरसरकारी वा स्वेच्छाचारी तवरले कुनै पनि वालवालिकाको स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन । वालवालिकाको गिरफ्तारी, थुना वा कैद कानून अनुरूप हुने र अन्तिम उपायको रूपमा र सबभन्दा कम समुचित समयावधिको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ ।^{५२} पक्ष राष्ट्रहरुले पन्ध्र वर्ष उमेर नपुगेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्ना सशस्त्र सेनामा भर्ना गर्ने छैनन् । पन्ध्र वर्ष उमेर पुगेका तर अठार वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट भर्ना गर्दा, पक्ष राष्ट्रहरुले बढी उमेरका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिने प्रयत्न गर्नेछन् ।^{५३}

३.७ अमेरिका

अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधनमा यस्तो भनिएको छ No State shall deny to any person within its Jurisdiction the equal protection of law^{५४}

अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनको जड नै जातिय भेदभाव हो र समान संरक्षणको व्यवस्था गरेका छैनन् । राष्ट्रपति केनडीले जारी गरेको उल्लिखित आदेश एवं सो आदेशलाई संशोधन नं. १४ मार्फत राष्ट्र रिचार्ड निक्सनले सन् १९७१ मा जारी गरेको संशोधन आदेशले संयुक्त राज्य अमेरिकामा अल्पसंख्यकहरुका लागि श्रम बजारमा Affirmative Action program लाई मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । यसैलाई आधार मानी राज्य कानूनहरुमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाहरु गरिएको पाइन्छ । अल्पसंख्यकको परिभाषाभित्र Negroes, American Indians, Orientals र Spanish जसलाई Americans भनिन्छ लाई समावेश गरिएको पाइन्छ । वर्तमानमा सरकारले यदि कुनै वर्ग, समुदाय वा समूहलाई फरक व्यवहार गर्ने गरी कुनै कानून निर्माण गर्छ भने त्यो कानून असंवैधानिक मानिदैन । सुरुका दिनहरुमा समान तर पृथक (Equal but separate) को मान्यता अनुसार समानताको व्याख्या (Plessy v. Ferguson, 1896) भएको तर पछि आएर सो मान्यतामा परिवर्तन आई समान तर पृथकको धारणा असमान हो भन्दै समानहरु बीच समानता (Equality among equals) को मान्यताअनुरूप गर्नुपर्ने भनी (Brown v. Board of Education, 1954) को मुद्दामा फैसला गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा रंगको आधारमा भेदभाव (Racial Discrimination) अन्त्य भएको पाइन्छ ।^{५५}

^{५०}. वाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९, धारा ३(१)

^{५१}. Ibid, धारा ३६

^{५२}. Id, धारा ३७

^{५३} Id, धारा ३८(३)

^{५४}. अमेरिकाको संविधान, १७८९, चौथो संशोधन धारा १

^{५५} Supra note 23, p. 186

३.८ बेलायत

संयुक्त अधिराज्यमा Equal pay Act, 1970, Sex Discrimination Act, 1975 र Race Relations Act, 1976 h:tf anti discrimination law ले Racial grounds, Colour, Race Nationality or Ethnics or National Origin का आधारमा हुने भेदभाव विरुद्ध नागरिकहरूलाई अधिकार एवं क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको पाइन्छ। यसका साथै Race Relations Act, 1976 ले निर्वाचित निकाय र रोजगारमूलक निकाय एवं संस्थाहरूमा महिलाहरूलाई न्यूनतम संख्यामा सीट प्रदान गर्ने आरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

३.९ भारत

भारतीय संविधानको धारा १५(१) र (२) ले धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, जन्म र यस्तै आधारमा नागरिकहरूका बीच विभेद रोक लगाएको छ। तर धारा १५(३) ले महिला तथा बालबालिकाका लागि राज्यद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १५(४) मा सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग वा अनुसूचित जाति र वर्गहरूको भलाईका लागि राज्यद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने कुरालाई मान्यता दिएको पाइन्छ।

भारतको संविधानको धारा १४ मा The State shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India^{५६}

भारतमा स्वतन्त्रता स्थापित हुनु अघिनै सकारात्मक विभेद सम्बन्धी अवधारण शुरु भैसकेको पाइन्छ। त्यहाँको मसुरी राज्यले सर्वप्रथम जातियताको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था लागु गरेको थियो, त्यस्तै कोल्हापुर मद्रास जस्ता राज्यले पनि जातियताको व्यवस्था लागु गरेको थियो, त्यस्तै कोल्हापुर मद्रास जस्ता राज्यले पनि जातियताको आधारमानै आरक्षण लागु गरेका थिए।^{५७} वर्तमानमा पनि सकारात्मक विभेद सम्बन्धी अभ्यास भारतमै उच्चतम विन्दु र प्रभावकारी रूपमा लागु गरिएको छ।

भारतको संविधानले राज्यद्वारा कसैलाई पनि कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने गरी धारा १४ मा व्यवस्था गरेको छ। धर्म, जात, जाति, लिंग वा उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, सार्वजनिक सेवामा अवसरको समान हक हुन तथा छुवाछुतको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ। मौलिक हकको प्रतिकुल हुने गरी बनाएका कानूनहरू बदर हुने गरी संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आत्मसात गरिएको छ। संविधानको धारा १४ देखि १८ सम्म समानताको हकसम्म सम्बन्धित अधिकारको व्यवस्था रहेका छन् जस अन्तर्गत जात, वर्ण, धर्म, लिंग र उत्पत्तिका आधारमा नागरिकबीच भेदभाव गर्न नहुने, सार्वजनिक पदमा नियुक्तका लागि जातजाति, धर्म, वर्ण र उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव नगरिने, छुवाछुत नगरीने र त्यस्तो कार्य गरेमा कानूनद्वारा दण्डनीय बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।

^{५६} भारतको संविधान, १९५० धारा १४

^{५७} Supra note 25

परिच्छेद-४

समानताको हक र सकारात्मक विभेद सम्बन्धी नेपालको व्यवस्था

यस परिच्छेदमा समानताको एक सकारात्मक विभेद सम्बन्धमा नेपालको संवैधानिक व्यवस्था आनूनी व्यवस्था र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलामध्ये महत्वपूर्ण फैसलाहरु मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

४.१ नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

नेपालको संवैधानिक विकासमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ ले समानताको छुट्टै अधिकारको व्यवस्था नगरी केवल उमेर पुगेका सबैले भोट दिन पाउने समान हकको व्यवस्था सम्म गरेको थियो ।

४.२. नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७

राज्य नीतिको लक्ष्य विशेष गरी निम्नलिखित हुनेछ ।

जीवन निर्वाह गर्न चाहिने पर्याप्त साधनमा नरनारी सबै नागरिकको समान हक गर्ने, स्त्री पुरुष दुवैलाई समान कामको लागि समान तलब दिलाउने, मजदुर स्त्री पुरुषको स्वास्थ्य र बल तथा केटाकेटीहरुको कलिलो उमेरको दुरुपयोग हुन नदिने र नागरिकहरुलाई आर्थिक परिस्थितिले निजहरुको उमेर वा बललाई नसुहाउने रोजगार गर्न बाध्य गर्न नदिने ।^{५८}

राज्यले विशेष ध्यान दिएर निर्वल वर्गको लागि शिक्षा र आर्थिक हित बढाउनेछ र उनीहरुलाई सामाजिक अन्याय र सब किसिमको शोषणबाट रक्षा गर्नेछ ।^{५९}

नेपाल राज्यभित्र ऐनको अगाडि सबैको समानता अथवा ऐनबाट हुने समान रक्षा जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि इन्कार गरिने छैन ।^{६०}

राज्यले धर्म, जातजाति, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान वा यस्ता कुनै विषयको आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई भेदभाव गर्नेछैन । तर राज्यले स्त्री जाति वा बालक वर्गको निमित्त कुनै खास व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।^{६१}

४.३ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणको हकदार हुनेछन्, सामान्य प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण लिंग जातजातिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन । कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग, जातजातिको आधारमा भेदभाव हुने छैन, तथा स्त्री, पुरुष दुवै थरीको लागि खुल्ला रहेको श्रमिकको हकमा लिंगको आधारमा पनि भेदभाव हुनेछैन ।^{६२}

^{५८}. नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७, धारा ४

^{५९}. Ibid धारा १०

^{६०}. Id धारा १३

^{६१}. Id धारा १४

^{६२}. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ धारा ४

४.४ नेपालको संविधान, २०१९

सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणका हकदार हुनेछन् सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन, सरकारी सेवा वा अरु दुवै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिको कुनै पनि नागरिकमाथि केवल, धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।^{६४}

४.५ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन । सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन । राज्यले नागरिकहरूका विच धर्म, लिंग, जातजाति वा वैचारिकआस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातीका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिनेछैन ।^{६५}

४.६ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

समानताको हकः^{६६} सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन ।

सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन । राज्यलले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्नेछैन । तर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक, वा साँस्कृतिक देखि पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्धा तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले लगाएको मानिने छैन ।

समान कामका लागि महिला र पुरुषका विचप रिश्रामिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन । छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक^{६७}

कुनैपनि व्यक्तिलाई जात, बंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

कुनैपनि व्यक्तिलाई जातजातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन

६४. Ibid धारा १७

६५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, धारा ११

६६. नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३, धारा १३

६७. Ibid, धारा १४

कुनै बस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गद्दु त्यस्तो सेवा, सुविधा वा बस्तु खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो बस्तु सेवा वा सुविधा कुनै खास जातिको व्यक्तिलाई मात्र विक्री वितरण गरिने छैन ।

कुनै जातजाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको ऊँचनिच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातिय सर्वोच्चता वा घृणाका आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातिय विभेदलाई कुनैपनि किसिमले प्रोत्साहित गर्न पाइने छैन ।

महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।^{६८}

महिला हकः^{६९} महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।

प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धि हक हुनेछ ।

कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ।

पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।

सामाजिक न्यायको हकः^{७०} आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

वालवालिका हकः^{७१} प्रत्येक वालवालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।

प्रत्येक वालवालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने छ ।

प्रत्येक वालवालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सडक वालवालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

कुनैपनि नावालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्व प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

राज्यको दायित्वः^{७२} वर्गीय जातिय, भाषिक, लैंगिक साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, पेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रिकृत एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने,

६८. Id, धारा १८(२)

६९. Id, धारा २०

७०. Id, धारा २१

७१. Id, धारा २२

७२. Id, धारा ३३(घ)(घ१)

मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंकहरुमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा हभागी गराउने ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुः ^{७३} देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि जाति, लिंग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी नीजि एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उन्नतिशील गराउनु राज्यको मुलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।

सबै किसिमको आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जातजाति, धर्म भाषा, वर्ण, समुदाय र सम्प्रदायका बिच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ ।

राज्यका नीतिहरुः ^{७४} विकास धर्म, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषा भाषिहरुका बीच समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकताको सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवा, खाद्यसम्प्रेषण र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा गरीबीको रेखमुका मजदुर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

वृद्ध, अशक्त महिला तथा बेरोजगारलाई कानूनमा व्यवस्था गरी दिने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

राजनैतिक दलहरुले उममेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तहरुलाई ध्यान दिनु पर्नेछ र खण्ड (ख) बमोजिम राजनैतिक दलहरुले उममेदवारहरुको सूचिकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत अन्य वर्ग समेतको कानूनमा व्यवस्था एबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ । ^{७५}

राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचनाः ^{७६} वर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिनेछ

।

७३. Id, धारा ३४(४)(५)

७४. Id, धारा ३५

७५. Id, धारा ६३(४)

७६. Id, धारा १३८

मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सिमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण साधन श्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।

राजश्व परिचालन र बाँडफाँड गर्दा मुलुकको सन्तुलित र समान विकास हुने गरी समाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोषबाट पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको समय उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ ।

विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलित लगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरु समेत रहने समावेशी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । ^{७८}

भाषा वा लिंगको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभावपूर्ण बन्देज लगाएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य चिन्ह वा झण्डा मुलुकको धार्मिक वा साम्प्रदायीक एकतालाई खलल पार्ने वा मुलुकलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको वा त्यस्तो दलको विधान वा नियमावलीमा निर्दलीय वा एकदलीय व्यवस्थाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने छैन । ^{७९}

नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानूनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिनेछ । ^{८०}

४.७ नेपालको संविधान, २०७२

समानताको हक धारा १८ उपधारा (१): सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।

उपधारा (२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीर अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।

उपधारा (३) राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।

पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।

(५) उपधारा (१) सबैको काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने,

(ज) उपधारा (१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमीकता दिदै जीवीकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने

उपधारा (७) युग सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगाएतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने,

उपधारा (१०) मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडावर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदाय भित्रमा विपन्न नागरिकको संरक्षण उत्थान, सशक्तिकरण र विकासमा अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,

उपधारा (११) उत्पीडित तथा पिछडाएका क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण र उत्थान सशक्तिकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,

(धारा ७० यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ

४.८ मुलुकी ऐन, २०२०

मुद्दा हेर्दा देहायको प्राथमिकताले कारवाई गर्दै जाँदा जुन मुद्दा पहिले छिन्न अंग पुग्छ सोही मुद्दा पहिला किनारा गर्नुपर्छ।^{८२}

थुनुवा कैदीको थुना वा कैद परेको मुद्दा,
वेवारिसे सोह्र वर्ष मुनिको नाबालकको मुद्दा,
तारीखमा रहेको पचहत्तर वर्षमाथिको बुढाबुढी र शारीरिक अशक्तता भएको व्यक्तिको मुद्दा,
स्वास्ती मानिस वादी वा पुनरावेदक भएको न्वारन गराई पाउँ वा नाता कायम गराई पाउँ भन्ने मुद्दा,
विधवा महिला वादी वा पुनरावेदक भएको मुद्दा,
माथि लेखिएको र त्यसपछि अरु मुद्दाको हकमा पुरानोको क्रमले

४.९ निजामती सेवा ऐन, २०४९

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्याछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ।^{८३}

- क) महिला- तेत्तीस प्रतिशत
- ख) आदिवासी/जनजाति- सत्ताईस प्रतिशत
- ग) मधेसी- बाइस प्रतिशत
- घ) दलित- नौ प्रतिशत
- ङ) अपाङ्ग- पाँच प्रतिशत
- च) पिछडिएको क्षेत्र- चार प्रतिशत

स्पष्टिकरण:

१) यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्भक्तनुपर्छ।

२) यस उपदफाको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनको लागि “महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित” भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्भक्तनुपर्छ।

८२. मुलुकी ऐन, २०२० दफा ११

८३. निजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा ७(७)

उम्मेदवार हुनको लागि योग्यता:^{८४}

देहायका व्यक्तिहरु निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन् ।

क) राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पुरा नभएका ।

ख) राजपत्र अनंकित र श्रेणी विहिन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका ।

ग) पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैंतीस वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा चालिस वर्ष उमेर पूरा भईसकेका, तर

१) भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ती भनी तोएको निजामति सेवाको पदमा चालिस वर्ष ननाघेका जुनसुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

२) राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा कर्मचारीको खुल्ला प्रतियोगितामा पैंतालिस वर्ष ननाघेका उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

३) निजामति सेवाका स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उम्मेदवार हद लाग्ने छैन ।

घ) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गरिएका,

ङ) गैर नेपाली नागरिक,

च) नैतिक पतन देखि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको,

नेपाल सरकारको विकास आयोजनाको वा विकासतर्फको कुनै पदमा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि खस्थायी नियुक्ती पाई अविच्छिन्न रुपमा सेवा गरिरहेका महिला कर्मचारीको हकमा खुल्ला प्रतियोगिताको लागि हुने लोकसेवा विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको बन्देज लाग्ने छैन ।^{८५}

निजामती सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी गरिनेछ ।^{८६}

बहुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्युनतम सेवा अवधि वा शैक्षिक योग्यता ^{८७} (१) बहुवाको निमित्त उम्मेदवार हुने पदको श्रेणी भन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र देहाय बमोजिमको न्युनतम सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्नेछ:-

क) राजपत्र अनङ्कित पदको निमित्त तीन वर्ष,

ख) राजपत्रांकित पदको निमित्त पाँच वर्ष

एकदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामति कर्मचारीहरुको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि पनि बहुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् ।

^{८४}. Ibid, दफा १०(१)

^{८५}. Ibid, दफा १०(२)

^{८६}. Id, दफा १६

^{८७}. Id, दफा २१

४.१० निजामती सेवा नियमावली, २०५०^{८८}

पदपूर्ति प्रतिशतको आधारमा पदसंख्या निर्धारण ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) को प्रयोजनको लागि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित समुदायको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ ।

तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोके सम्मको लागि सम्पूर्ण महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको समुदाय मानिनेछ ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ बमोजिम छुट्याइएका पदमा दरखास्त दिँदा देहायका आधारमा दिनुपर्नेछ -

क) आदिवासी/जनजातिका हकमा नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सुचिकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीका आधारमा, तर नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सुचिकृत भएको जातिभित्र एक भन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सुचिकृत भएको जाति भित्र थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने छ ।

ख) दलितको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचिकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा, तर राष्ट्रिय दलित सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचिकृत भएको जाति भित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

ग) अपाङ्गका हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाजकल्याण परिषदबाट अपाङ्गता प्रमाणित गरेको आधारमा,

घ) मधेसीका हकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा, तर निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरई दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

ङ) पिछडिएको क्षेत्रका हकमा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोवास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोवास भएको भनी प्रमाणित गरेको आधारमा ।

पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: ^{८९} (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (८) बमोजिम निर्धारित मद्दमध्ये कुन पद कुन किसिमका अपाङ्गहरुको लागि अनुपयुक्त हुने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाश गरी तोकेबमोजिम हुनेछ ।

२) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) बमोजिम महिला विकास कार्यक्रमका स्थायी पदमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा महिला विकास विभाग अन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला स्थित महिला विकास कार्यक्रमका विकासबाट साधारणमा परिणत भएका स्थायी पदका लागि प्रतिस्पर्धा गराउनेछ । यसरी प्रतिस्पर्धा गराउँदा समान पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने छ ।

^{८८} निजामती सेवा नियमावली, २०५० नियम १४

^{८९} नियम १४क

४.११ बालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८

बालकको पालनपोषण शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचारमा छोरा वा छोरीको आधारमा मात्र वा छोराछोरा वा छोरी छोरीको बिच कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन ।^{९०}

कुनै स्त्री पुरुषको वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनु अघि वा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई सकेपछि जन्मेका बालकहरुको पालनपोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्योपचारमा कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन ,
आफूले जन्माएको बालक तथा आफूले राखेको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको बीच कुनै किसिमको भेदभाव गर्नु हुँदैन ।^{९१}

बालक र अपराधिक दायित्व: ^{९२} कानून बमोजिम अपराध ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्ति सो काम गर्दा दश वर्ष मुनिको बालक रहेका भने निजलाई कुनै प्रकारको सजाय हुन सक्दैन ।

बालकको उमेर दश वर्ष वा सो भन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम रहेछ भने निजलाई कानून बमोजिम जरिवाना हुने कुनै अपराध गरेकोमा हप्काई, सम्झाई र कैद हुने अपराध गरेकोमा कसुर हर ६ महिना सम्म कैद हुन्छ ।

चौध वर्ष वा सो भन्दा माथि र साह्र वर्ष भन्दा मुनिको बालकले कुनै अपराध गरे निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने आधा सजाय हुन्छ ।

अयोग्यता वा कायम नहुने:^{९३} कुनै अपराध गरेको कारणबाट कानून बमोजिम कुनै पद वा सुविधा प्राप्त गर्न कुनै व्यक्ति अयोग्य हुने रहेछ भने पनि वाल्यवस्थामा गरेको त्यस्तो अपराधबाट त्यस किसिमको अयोग्यता निजको हकमा सिर्जना भएको मानिने छैन ।

सजाय गर्ने प्रयोजनको निमित्त पटक कायम गर्दा वाल्यवस्थामा गरेको अपराधको गना गरिने छैन ।

बालकले एउटै अपराध एक पटक भन्दा माथि गरेको भए पनि पटकको आधारमा निजलाई थप सजाय गरिने छैन ।

कानून व्यवसायी नभएमा बालकको मुद्दामा कारवाई किनारा हुने: ^{९४} कुनै बालकको विरुद्ध लगाइएको फौजदारी अभियोगमा निको प्रतिरक्षागर्ने कानून व्यवसायी नभएमा अदालतले मुद्दाको कारवाही वा किनारा गर्ने छैन ।

उपदफा (१) मा उल्लेखित अवस्थामा सम्बन्धित अदालतले नै नेपाल सरकारको तर्फबाट नियुक्त भएको वैतनिक कानून व्यवसायी वा अन्य कुनै इच्छुक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराई दिनुपर्छ ।

।

^{९०}. बालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, दफा ५

^{९१}. Ibid, दफा ६

^{९२}. Id, दफा ११

^{९३}. Id, दफा १२

^{९४}. Id, दफा १९

बालक सम्बन्धी खास व्यक्ति मात्र उपस्थित हुन पाउने:^{९५} यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम बालक सम्बन्धी कुनै मुद्दाको कारवाई चल्दा कानून व्यवसायी, बालकको बाबु, आमा, नातेदार वा संरक्षक र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपयुक्त

देखि अनुमति दिएमा बालकको हक हित संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न कुनै व्यक्ति वा सामाजिक संस्थाको प्रतिनिधि इजलासमा उपस्थित हुन सक्नेछ ।

उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा तथा सो सँग सम्बन्धित घटनाको विवरण मुद्दाको तहकिकात गर्ने वा मुद्दा हेर्न अधिकारीको अनुमति वेगर कुनै पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न पाइने छैन । यस्तो प्रतिबन्ध सम्वाददाता तथा सम्वाद फटो प्रतिनिधिको हकमा समेत लागु हुने छ ।

मुद्दाको तहकिकात तथा सजायको स्थगन:^{९६} प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको तहकिकात गर्नुपर्ने कुनै कसुरको अभियोग लागेको बालकको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थिति र थुनामा बस्नु पर्ने ठाउँलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई थुनामा राख्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा चाहिएको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा निजको बाबु, आमा, नातेदार वा संरक्षकको जिम्मा लगाई वा बालकको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न कुनै सामाजिक संस्था वा बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको तहकिकात वा पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको बालकलाई निजको शारीरिक अवस्था, उमेर कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गरेको पटक, आदिको विचार गर्दा कारागारमा राख्न उपयुक्त नहुने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा त्यसरी तोकिएको सजाय तत्काल भोग्नु नपर्ने गरी स्थगित राख्न वा त्यसरी तोकिएको सजायको अवधि कुनै बाल सुधार गृहमा बसी वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको संरक्षणमा रही व्यक्ति गर्नुपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । यसरी सजाय स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले त्यसको एक वर्ष भित्र त्यही वा अन्य कुनै कसुर गरे वापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा यो समेत खापी एकै पटक दुवै कैदको सजाय कार्यन्वित गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ ।

बालकको तर्फबाट मुद्दा गर्न पाउने:^{९७} बालकको हक पुग्ने जुनसुकै कुरामा नालिस उजुर वा प्रतिरक्षा गर्नु गर्दा निजको बाबु, आमा वा संरक्षकले नालिस, उजुर गर्न वा प्रतिरक्षा हकवालालाई सो अधिकार प्राप्त हुनेछ ।

यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दा जुनसुकै व्यक्ति वा नेपाल सरकारको उजुरीबाट चल्न सक्नेछ ।

बालक सम्बन्धी तथ्यांक र त्यसको प्रयोगमा बन्देज:^{९८} प्रहरी कार्यालयले कुनै कसुरको अभियोगमा पक्राउ परेको बालकको नाम ठेगाना, उमेर, लिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, निजले गरेको कसूर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही चलाइएको भए सो सम्बन्धी विवरण खुलाई गोप्य रुपमा तथ्यांक राख्नु पर्छ र त्यसको तथ्यांकको उतार छ/छ ममहिनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।

उपदफा (१) बमोजिम राखिएको तथ्यांक कुनै अध्ययन वा शोध कार्यको निमित्त प्रकाशित गर्नु परेमा बालकको नाम, थर वा ठेगाना उल्लेख नगरी उमेर वा लिंगको आधारमा सम्म प्रकाशित गर्न सकिने छ ।

मुद्दाको कारवाईमा प्राथमिकता दिनुपर्ने : ^{९९} यस ऐन अन्तर्गत कुनै बालक वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको प्राथमिकता दिई कारवाई र किनारा गर्नुपर्छ ।

९५. Id, दफा ४९

९६. Id, दफा ५०

९७. Id, दफा ५१

९८. Id, दफा ५२

९९. Id, दफा ५७

जग्गाको विक्री वितरण:^{१००} यस ऐन बमोजिम प्राप्त भएको वा जफत भएको जग्गा जुन गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाका स्थानीय व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम विक्री वितरण गर्नेछ । यसरी विक्री वितरण गर्दा स्थानिय भूमिहीन व्यक्तिमध्ये मुक्त कमया, दलित, आदिवासी र जनजातिलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

मोहीको एक र दायित्व: ^{१०१} यस परिच्छेदको अन्य दफाहरुको अधिनमा रही मोहलि कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको एकासगोलका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोरा, बुहारी, नाति, नातिनी, बुहारी, दाजुभाई वा दिदी बहिनीहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ ।

४.१३ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२

कुनै विशेष वर्गको निमित्त विशेष व्यवस्था गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार १०२ माथि दफा ३ र ४ मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि:

क) स्त्री जाती वालकवर्ग र कुनै अनुन्तत नागरिकवर्गको लागि विशेष व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अधिकार हुने छ ।

ख) धर्म, गुठी सदावर्त इत्यादिको हकमा प्रचलित ऐन नियम रितिथिति बमोजिम हुनेछ, यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।

नावालकलाई फेक्टरी इत्यादिमा काम लगाउनमा निषेध: चौध वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै वालकलाई पनि कुनै कारखाना वा खानीको काममा लगाउन वा अरु कुनै जोखिमी काममा भर्ना गर्न हुँदैन ।

४.१५ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८

निरीक्षण र मूल्यांकन गर्ने: ^{१०४} निरीक्षण गर्ने न्यायधीशले खास गरी देहायका मुद्दा सम्बन्धी मिसिलहरु अनिवार्य रुपमा निरीक्षण गर्नुपर्छ:

क) पुर्पक्षको लागि थुनामा रहको व्यक्तिको मुद्दा,

ख) पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएका मुद्दाहरु मध्ये केहिका मुद्दाहरु,

ग) पक्षको रुपमा वालक, कृद्ध, महिला वा अपाङ्ग सम्मिलित रहेका मुद्दा, र

घ) सार्वजनिक सरोकार वा महत्वको विषय समावेश भएको मुद्दा ।

१००. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा २१

१०१. Ibid, दफा २६

१०२. नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ दफा ५

१०३. Ibid, दफा १४

१०४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८, दफा २०

४.१५ कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४

कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरूप सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितो संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले, ^{१०५}

४.१६ कोर्ट फि ऐन, २०१७

कोर्ट फि निर्त नसक्नेको मुद्दा हेरिन सक्ने: ^{१०६} यस ऐनको अन्य दफामा जनुसुकै कुरा लेखिएको भएतापिन देहायमा लेखिएको अवस्थामा मुद्दा हेर्न अधिकृत वा न्यायाधीशले कारण सहितको पर्चा खडा गरी केही वा कोर्ट फी पछि लिने गरी नालेस, उजूर, पुनरावेदन वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन दर्ता गर्ने आदेश गर्न सक्नेछ:-

नालेस, उजूर वा पुनरावेदन गर्ने वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन दर्ता गर्ने आदेश गर्न सक्नेछ । नालेस, उजूर वा पुनरावेदन गर्ने वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याउन निवेदन दिने व्यक्तित नितान्त गरीब भई लाग्ने कोर्ट फी सबै वा केही बुझाउन असमर्थछ भन्ने मुद्दा हेर्ने अधिकृत वा न्यायाधीशलाई विश्वास गर्नुपर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा,

नालेस, उजूर वा पुनरावेदन गर्ने वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याउन निवेदन दिने व्यक्तिको भ्रगडा गरेको वस्तु बाहेक अरु जायजेथा केही नभई कोर्ट फी दाखिला गर्न असमर्थ छ भनी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट सिफारिस भई आएमा वा मुद्दा हेर्ने अधिकृत वा न्यायाधीशलाई सो कुराको विश्वास गर्नु पर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा ।

४.१७ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

वडा समितिको गठन: ^{१०७} गाउँ विकास समितिको प्रत्येक वडाका प्रचलित कानून बमोजिम मतदाता हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले दफा १० बमोजिम गाउँ परिषद्को सदस्यको लागि चाहिने योग्यता पुगेको व्यक्तिहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका हेदाय बमोजिमका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू रहने गरी एक वडा समिति गठन हुने छ ।

क) एक जना वडाध्यक्ष,

ख) एक जना महिला वडा सदस्य र

ग) तीन जना वडा सदस्यहरू

गाउँ परिषद्को गठन: ^{१०८} दफा ४ बमोजिम तोकिएको गाउँ विकास क्षेत्रमा एक गाउँ परिषद् गठन गरिनेछ ।

गाउँ परिषदमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन् :-

क) गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,

ख) प्रत्येक वडा समितिका वडाध्यक्ष, महिला वडा सस्य र वडा सस्यहरू

ग) गाउँ विकास क्षेत्रभित्रका एक जना महिलासहित समाजसेवी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण ले पिछडिएका जाति, जनजाति, दलित तथा आदिवासी मध्ये गाउँ परिषदद्वारा मनोनित छ जना व्यक्तिहरू ।

^{१०५}. कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४, प्रस्तावना

^{१०६}. कोर्ट फि ऐन, २०१७, दफा २२

^{१०७}. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, दफा ७

^{१०८}. Ibid, दफा ८

गाउँ विकास समितिको गठन: ^{१०९} दफा ४ बमोजिम तोकिएको गाउँ विकास क्षेत्रमा गाउँ परिषदको कार्यकारीणीको रूपमा एक गाउँ विकास समिति गठन गरिनेछ ।

गाउँ विकास समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्: दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमका गाउँ परिषद्का सदस्यहरू मध्येबाट एकजना महिला सहित गाउँ विकास समितिद्वारा मनोनित दुई जना सदस्यहरू ।

गाउँ विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: ^{११०} गाउँ परिषदको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनुको अतिरिक्त गाउँ विकास समितिको नाम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी:

आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त पिछडिएका उत्पीडित जनजातिहरूका छात्र-छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाउने ।

विविध:

गाउँ विकास क्षेत्रभित्रका महिलाहरूको उत्थानको लागि आवश्यक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

गाउँ विकास समितिको योजनाको तर्जुमा: ^{१११} गाउँ विकास समितिले योजनाको तर्जुमा गर्दा देहाय बमोजिमका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ:-

पिछडिएका वर्ग तथा महिला वर्ग र बालबालिकालाई पत्येक्ष लाभ हुने । आवाधिक योजना तर्जुमा गर्दा निम्न विषय समावेश गर्नु पर्नेछ,

पिछडिएका जातजातिहरू एवं गरीबी भएको क्षेत्र तथा त्यस क्षेत्रमा गरिएका वा गरिनुपर्ने विभिन्न विकास कार्यहरू ।

महिला र बालबालिकाको लागि आयमूलक र सीप मूलक विकास कार्यहरू ।

नगर परिषदको गठन: ^{११२} दफा ७२ बमोजिम तोकिएको नगर क्षेत्रमा एक नगर परिषद गठन गरिनेछ ।

नगर परिषदमा देहायबमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्:-

क) नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख,

ख) प्रत्येक वडा समितिका वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य र वडा सदस्यहरू,

ग) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका महिलासहित समाज सेवी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएका जाति, जनजाति, दलित तथा आदिवासी मध्ये नगर परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गका दफा ७८ बमोजिम नगर परिषदको सदस्यको लागि चाहिने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नगर परिषद्द्वारा मनोनित कम्तीमा ६ जना र बढीमा २० जना व्यक्तिहरू ।

प्राथमिकता निर्धारण: ^{११३} जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्दा निम्नबमोजिमको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ

क) पिछडिएको तथा उत्पीडित जाति, जनजाति, एवं महिला र बालबालिकाको लागि आयमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रमहरू ।

^{१०९}. Id, दफा १२

^{११०}. Id, दफा २८

^{१११}. Id, दफा ४३

^{११२}. Id, दफा ७६

^{११३}. Id, दफा २०१

४.१८ संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४

उम्मेदवारको बन्दसूची: ११४ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनको लागि त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दलले आफ्नो दलको तर्फबाट उठाउने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ ।

उपदफा (१) बमोजिम राजनैतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत सदस्यको उम्मेदवारी दिने त्यस्तो बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ ।

राजनैतिक दलले उम्मेदवार सूचीकृत गर्दा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी लगायत अन्य समेतको जनसंख्या प्रतिशतको आधार समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुसूची-२ बमोजिम उम्मेदवार बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने छ । यसरी महिलाको उम्मेदवारी सुचिकृत गर्दा दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी र अन्य समूह समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्त अनुरूप गर्नुपर्नेछ । मधेशीबाट उम्मेदवार चयन गर्दा दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य समूह समेतको जनसंख्या प्रतिशतको त्यसरी तयार गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगले तोकेको समयवधिभित्र सम्बन्धित राजनैतिक दलले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।

स्पष्टीकरण:

१. यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “जनसंख्या प्रतिशतको आधार” भन्नेले संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अधिको राष्ट्रिय जनगणना बमोजिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधार सम्भन्धनु पर्छ ।

२. यस उपदफा बमोजिम राजनैतिक दलले उम्मेदवार सूचीकृत गर्दा उत्पीडित समूह, गरीब, किसान, मजदुर र अपाङ्ग समेतको व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई समुचित ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने छ ।

३. दफा ६ को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम दिइने महिला उम्मेदवारको संख्यामा दफा ५ को पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार दिइने महिला उम्मेदवारको संख्या जोडेर कुल संख्यामा न्यूनतम एक तिहाई महिला उम्मेदवार हुनु पर्नेछ ।

नेपालको संवैधानिक विकासमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ ले समानताको छुट्टै अधिकारको व्याख्या नगरी केवल उमेर पुगेका सबैले भोट दिन पाउने समान हकको व्यवस्थासम्म गरेको थियो । मौलिक हकको छुट्टै व्यवस्थापन नगरी सबै व्यवस्थाहरु निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राखिएको नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा १३ ले ऐनका अगाडि सबैको समानता वा ऐनबाट हुने समानरक्षा कसैलाई पनि इन्कार नगरिने व्यवस्था गरि सर्वप्रथम कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षणको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ४ ले सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणको हकदार हुने, नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जातिका आधारमा भेदभाव नगरिने सरकारी सेवाको लागि लिंगको आधारमा भेदभाव नहुने र जात जातिका आधारमा जनताबीच घृणा, द्वेष फैलाउन नहुने व्यवस्था समेत गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १० ले सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणका हकदार हुने, सामान्य आनूनको प्रयोगमा नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नहुने र सरकारी वा सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा नागरिकमाथि धर्म, लिंग, जात, जाति, जाती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वप्रथम सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको थियो । उक्त संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा

११४. संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ दफा ७

मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यस व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि निरन्तरता दिएको र २०४७ को संविधानले भन्दा अलि फरक र विस्तृत रुपमा यस संविधानको धारा १८(१) प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्था बाहेक अन्य केहि कानूनी व्यवस्थाहरु पनि हामी कहा रहेका छन् । उल्लेखित ऐन नियमहरुमा पनि धेरैथोरै सकारात्मक विभेदको बारेमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

नेपालका लागि सकारात्मक विभेद नयाँ अवधारणा हो । सर्वप्रथम २०४७ सालको संविधानले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भएपनि उक्त संविधानको कार्यकाल भरी नै संविधानले परिलक्ष्य गरे अनुसार उक्त संविधानको धार ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानून निर्माण भै उनीहरुको संरक्षण वा विकासका लागि राज्यद्वारा कुनै कार्य हुन सकेन । जसलाई उक्त संविधान असफल हुनुको प्रमुख कारणका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । वर्तमान संविधान अन्तरिम संविधान भै यसको कार्यकाल ज्यादै छोटो समय भएकाले गर्दा यस संविधान अन्तर्गत समेत धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यशले लिएको लक्ष्य पूरा हुनसक्ने देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाहरुमा केही भिन्नता रहेको पाइन्छ । ती निम्न छन्:-

- २०४७ को संविधानले महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा वर्तमान संविधानले त्यसको दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान र मजदुर वर्गलाई समेत थप गरेको छ ।

- २०४७ को संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा वर्तमान संविधानले शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गलाई यसबाट हटाईए सो को सट्टामा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गलाई समावेश गरेको छ ।

- २०४७ को संविधानले यस्ता वर्गहरुको संरक्षण र विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा वर्तमान संविधानले त्यसमा सशक्तिकरण भन्ने शब्द थप गरेको छ ।

वर्तमान संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले राज्यलाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने गरी शक्ति प्रदान गरेको भएपनि उनीहरुको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि के कस्ता कार्यक्रम वा व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ र कुन वर्गका लागि संरक्षण, कुन वर्गका लागि सशक्तिकरण र कुन वर्गका लागि विकासको विशेष व्यवस्था आवश्यक पर्दछ र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान वा मजदुर अन्तर्गत कानूनद्वारा विशेष संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको अवसर प्राप्त गरेकाले आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएको वर्ग अन्तर्गत पुनः संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको अवसर प्राप्त गर्न सक्दछन् वा सक्दैनन र नसक्ने भएमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान वा मजदुर बाहेक आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएको वर्ग अन्य कुन हुन सक्छ र आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएको वर्ग भन्नाले कुन वर्गलाई जनाउँदछ र त्यसको पहिचानका आधारमा आगामी दिनमा सरकार एवं न्यायपालिका दुवैका लागि यो विषय गम्भीर चुनौतीको रुपमा उपस्थित हुन सक्दछ ।

४.१९ सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाहरु:

१. मनबहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत^{११४}

कुनै ऐनको कुनै दफामा द्विविधाजनक अर्थ आउने अथवा भ्रम वा कुनै किसिमको अस्पष्टताको स्थिति नरहोस् भन्नाका लागि कानून तर्जुमा प्रविधिमा त्यस्तो भ्रम वा अस्पष्टताको संभावना रहेको दफापछि स्पष्टिकरण राख्ने गरिएको पाइदा उक्त स्पष्टीकरण सम्बन्धित दफाको अभिन्न अंग हुने ।

अदालको महलको १०(क) नं. को स्पष्टिकरणले यस्तो कार्य भेदभावपूर्ण मानिने छैन भनी गरेको अपवादात्मक प्रकृति र परिमाणको व्यवस्था संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नभएको पुष्टि हुने ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई साँघुर्याउने अपवादित गर्ने कार्य गरेको हदसम्म अदाल १० क को स्पष्टिकरण धारा ११(४) सँग बाभिएको देखिने ।

२. महिला, कानून र विकास मञ्च र आफ्नै तर्फबाट समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत^{११६}

लोग्ने वा स्वास्नी मानिस दुवैमा हुनसक्ने सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता केवल स्वास्नी मानिससँग मात्र हुन्छ, लोग्नेमानिसमा हुँदैन भन्ने आशय आउने प्रकृतिको कानून निर्माण गर्नु र लागु गर्न संवैधानिक प्रावधान र समानताको सिद्धान्त अनुकूल नहुने ।

३. महिला, कानून र विकास मञ्च र आफ्नै तर्फबाट समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत^{११७}

स्वास्नी मानिसले कुनै लोग्ने मानिसलाई आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्तिको कुनै व्यहोरा ले हक हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यही व्यक्तिसाग विवाह गरेमा अदिको उक्त व्यवहार सदर नहुने, लोग्नेमानिसले गरेमा भने सदर हुने भई महिला र पुरुषबीच भेदभावपूर्ण प्रावधान रहेन ।

स्वास्नी मानिसको आफ्नो हक पुग्ने अरु कसैको हक नलाग्ने सम्पत्ति आफूखुश प्रयोग गर्न पाउने स्वामित्वको अधिकार र विवाहको अधिकार दुई भिन्न र सार्थक अधिकारहरु हुन् । एउटा निर्वाध हकको प्रयोग गर्दा अर्को त्यस्तै हक अधिकारमा संकुचन ल्याउने गरी बनेको कानूनलाई न्यायोचित र तर्कसंगत मान्न नमिल्ने ।

४. छुवाछुत विरुद्ध वकीलहरुको राष्ट्रिय अभियान -ल्यानकाउ नेपाल) र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता रत्नबहादुर वागचन्द समेत वि. प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत^{११८}

संविधानले मानव अधिकार र मौलिक हक प्रदान गरी मौलिक हक अपहरण भएमा असाधारण अधिकार प्रगा गरी हक प्रचलन गराउन सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त भएको कारण राज्यले नागरिक नागरिकबीच समान अवस्थाका व्यक्तिलाई सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव गर्न नसक्ने ।

११४. ने.का.प. २०४९, अंक १२, नि.नं ४६७० पृष्ठ १०१०

११६. सर्वोच्च अदालत, विषयगत नजीर संग्रह २०६६, भाग ३, मानव अधिकार तथा लैङ्गिक न्याय, पृष्ठ ७

११७. ने.का.प. २०६३, नि.नं ९७९

११८. सर्वोच्च अदालत, विषयगत नजीर संग्रह २०६६, भाग ३, मानव अधिकार तथा लैङ्गिक न्याय, पृष्ठ १६३

राज्यले संविधान तथा सबै किसिमको जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्ध अनुसार जातीय भेदभावमा प्रतिबन्ध लगाई जातिय भेदभाव दण्डनीय हुने कानून निर्माण गरी तत्कालिन संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था अनुसार उल्लिखित Merginalized वर्गको लागि आरक्षण प्रदान गर्ने विशेष कानून निर्माण गर्नु पर्ने ।

५. नीलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्त वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत ^{११९}

संविधानको धारा ३ का मौलिक हक र नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल कानून सरह लागु भएका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरुले दिएको अधिकार आफ्नै पहिचानमा उपयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ भने त्यस्तो व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी (Arbitrary), आधारहिन (Unreasonable) र भेदभावयुक्त (Discriminatory) मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो कानून कार्यान्वयन गर्ने राज्यको कार्य पनि Arbitrary, Unreasonable र Discriminatory नै मान्नुपर्ने ।

६. जीतकुमारी पंगेनी (न्यौपाने) समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत ^{१२०}

जबरजस्ती करणीको महलमा भएको व्यवस्थाको बलत्कारलाई जघन्य फौजदारी अपराध नामाकरण गरेको अवस्थामा अपराधको परिणाम एउटै हुने भएपछि सजायमा वैवाहिक बलात्कार र गैरवैवाहिक बलात्कार बीचमा भिन्नता गर्नुको कुनै औचित्यपूर्ण आधार नरहने ।

अपराध, आपराधिक कार्य गरे बापत हुने भएकोले कर्ताको हैसियतको भिन्नताले सजायमा कमी गर्ने हैन भने संविधानले अंगिकार गरेको समानताको सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको हुन जाने ।

७. महिला कानून र विकास मञ्च र आफ्नै तर्फबाट समेत अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत ^{१२१}

सम्पति सम्बन्धी कानूनले जन्म र वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यतासम्म दिएको तर विभेद नगरेको हुँदा मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको १(क) नं. मा भएको व्यवस्था संविधानसँग वा समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको समेत देखिन नआउने ।

अपुताली भन्ने कुरा स्वाभाविक रुपमा नजिकको हकवालाले पाउने हुँदा ऐनमा उल्लिखित क्रमका हकवाला भएसम्म विवाहित छोरीले अपुताली नपाउने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नसकिने ।

८. महिला, कानून र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट समेत सपना प्रधान मल्ल समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत ^{१२२}

वृत्ति विकासका थप अवसरहरु दिने वा मूल प्रवाहमा ल्याउने भन्दा भएका अवसरहरुमा पनि कुनै न कुनै आधारमा बञ्छना गरिन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक विभेद गरिएको भनी मान्न नसकिने ।

११९ ने.का.प. २०६५, नि.नं ७९५८ पृष्ठ ४८५

१२० ने.का.प. २०६५, नि.नं ७९७३ पृष्ठ ६६४

१२१ ने.का.प. २०६५, नि.नं ८०३१ पृष्ठ १३०६

१२२. सर्वोच्च अदालत, विषयगत नजीर संग्रह २०६६, भाग ३, मानव अधिकार तथा लैङ्गिक न्याय, पृष्ठ ४८०

९. प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सिंहदरवार समेत ^{१२३}

महिला कामदार तथा कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अधिपछि गरी लिन पाउने प्रसुति विदापछि विदाकै एक प्रकार भएको सन्दर्भमा प्रसुति विदा संविधान प्रदत्त हक, अधिकारको विषय नभएकोले सो विदा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा उल्लेखित समानताको हक विपरीत रहेको अर्थ गर्न नमिल्ने ।

नवजात शिशुको अधिकार भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा त्यसवखत महिलालाई फुर्सदको समयको आवश्यकता पर्ने कुरालाई नकार्न नमिल्ने ।

महिलाहरुलाई गर्भावस्थादेखि लिएर सुत्केरी भैसकेको निश्चित समयसम्म विशेष सुरक्षित वातावरणको आवश्यकता पर्ने हुँदा उनीहरुको पोषण, स्याहार संभार तथा स्वास्थ्यको विशेष व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने ।

१०. सुदर्शन सुवेदी समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत ^{१२४}

अन्धा, अपाङ्ग, वहिरा तथा सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्तिहरुलाई नेपाल अधिराज्यभरीका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तालिम केन्द्रहरुमा निःशुल्क भर्ना गरी गराई निजहरुबाट भर्ना भएपछि कुनैपनि किसिमको सेवा शुल्क नलिनु, लिन नलगनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

११. अधिवक्ता रेश्मा थापा समेत विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत ^{१२५}

बोक्सीको निराधार र अनय विश्वासी आरोप लगाई कुनै पनि स्त्रीलाई नग्न पारी गाउँ घुमाउनु, मानिसको दिशा घोली खुवाउनु जस्ता अति अमानुषित व्यवहार गरी महिलाको अस्मिता, इज्जत, मान प्रतिष्ठामा आघात पुःउने गरी गर्ने सम्पूर्ण क्रिया अपराधिक क्रियाकै श्रेणीभित्र पर्ने ।

१२. प्रद्योश क्षेत्री समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत ^{१२६}

संविधानको धारा १३(३) ले समान र असमान दुई अवसरलाई मध्येनजर राखेको छ । समान अवस्थामा धर्म, वर्ण, लिंग, जातजातिका आधारमा भेदभाव नगरिने संवैधानिक व्यवस्था गनेकोमा सोही धाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले असमान अवस्था अर्थात महिला, बालक, वृद्ध शारीरिक वा मानसिकरूपले असक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक शैक्षिक दृष्टिले पिछ्छिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने ।

कानून बनाएर मात्र विषेश व्यवस्था गर्न सकिने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले उल्लेखित वर्ग तथा महिलाहरुको आरक्षण प्रणालीलाई अरु दिर्ग स्थाई बनाई कार्यकारिणीको प्रशासनिक तरङ्गमा मात्र संचालन नगरिने भन्ने लक्ष्य लिएको देखिँदा भारतको संविधानको धारा १५(३) (४) धारा १६(४) का सम्बन्धमा भएका निर्णय प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक नदेखिने ।

^{१२३} ने.का.प. २०६०, नि.नं ७२६८, पृष्ठ ७२६

^{१२४} सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सार्वजनिक कल्याण सम्बन्धि केही महत्पूर्ण नजीरहरु पृष्ठ, १७१

^{१२५} Ibid पृष्ठ २१२

^{१२६} ने.का.प. २०६१, नि.नं ७४१२, पृष्ठ ९०१

१३. अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावली समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत^{१२७}

उही अवस्थामा लोग्ने मानिसले स्वास्थ्य जीवित हुँदै र सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गर्न पाउने वा अर्को स्वास्थ्य राख्न पाउने र तर स्वास्थ्यमानिसले विवाह गरेमा वा अर्को लोग्ने राखेमा सजायको भागि हुनुपर्ने व्यवस्थालाई वैवाहिक विभेदकारी व्यवस्थाको संज्ञा दिनुपर्ने

विहावारीको ९ नं. को सशर्तात्मकरूपमा लोग्नेमानिसले मात्र बहुविवाह गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था महिला र पुरुष बीच वैवाहिक रूपमा गरिएको विभेद स्पष्टरूपमा देखिन आउने ।

१४. अधिवक्ता रत्न बहादुर वागचन्द समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत^{१२८}

जातिपाती छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यहरु नागरिक नागरिक बीचको समानताको विरुद्ध हुने र यले सामाजिक विकृति निम्ताई राष्ट्रिय उत्थानमा बाधक हुने कुरामा कसैको दुईमत हुन नसक्ने भएकोले समाजमा व्याप्त रहेको कुरीति सिर्फ कानून बनाएर मात्र जान नसक्ने हुँदा अशिक्षाको कारणले समाजमा देखिरहेको कुरीति उताउनलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका उद्देश्यमूलक कार्यक्रम लागू गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशनात्मक आदेशसम्म जारी हुने ।

१५. अधिवक्ता टेक ताम्रकार समेत विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत^{१२९}

जन्म, मृत्यु तथा अनय व्यक्तिगत घटना -दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड -क) मा रहेको “जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मुख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको पुरुषहरु मध्ये सबै भन्दा जेठी व्यक्तिले”भन्ने व्यवस्थामा रहेको “पुरुषहरुमध्ये”भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा १३१ अनुसार निष्क्रिय हुने ।

वादी समुदायका वालवालिकाहरु लगायत बाबुको ठेगान नलागेको सबै वालवालिकाहरुलाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने निजहरुको जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु तथा त्यस्ता वालवालिकालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ को उपधारा (२) तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा(४)(४) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ।

१६. पुण्यवती पाठक समेत विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय समेत^{१३०}

महिलावर्गलाई पुरुषलाई भन्दा बढी Hardship हुनेगरी गरिएको कुनै पनि कार्यकारीणी निर्णय जसको जतिसुकै Bonafide intention भएपनि त्यस्तो निर्णयलाई कानूनी राज्यको मान्य सिद्धान्त विपरित discriminatory, excess of power / arbitrary निर्णय मान्नु पर्ने ।

महिलाहरुलाई राहदानी जारी नगर्ने हो भने महिलाहरुलाई ICCPR ले दिएका स्वतन्त्रताहरु उपभोगमा अनुचित बन्देज लाग्न जान्छ । कानूनले दिएको अधिकार बेगर महिलावर्गलाई मात्र ती स्वतन्त्रताहरु उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुने गरी कार्य कारीणीले निर्णय गर्न नसक्ने ।

१२७. सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सार्वजनिक कल्याणसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नरिहरु (२०१५-२०६२) भाग ८, पृष्ठ २६१

१२८. Ibid पृष्ठ ३०१

१२९. Id पृष्ठ ३२३

१३०. Ibid पृष्ठ ३३९

१७. केदार मैनाली विरुद्ध संचालक समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत^{१३१}

समानताको हकको प्रथम शर्त कानूनको दृष्टिमा अर्थात् कानूनको समानतापूर्ण नीति र व्यवहारको सुनिश्चिततामा हुने ।

राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा विभेद गर्न नहुने । नागरिकको समानताको हक भन्नाले समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने हुने ।

ऐन नियममा भएको व्यवस्थालाई नयाँ ऐन नियमले जेजति हदसम्म निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षण गर्नेको छ, सो हदसम्म मात्र कायम रहने हो । सो बाहेक पुरानो खारेज भैसकेको ऐन नियमको व्यवस्था कायम रहन नसक्ने ।

पुरानो नियमको व्यवस्थालाई नयाँ ऐन नियमले निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षण दिएकोमा पनि त्यसपछि आएको ऐन नियमले सो निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षणको व्यवस्था कायम राखेन भने त्यसरी निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षण गर्नाले छागेको मितिदेखि सो व्यवस्था स्वतः खारेज भए सरह हुने ।

१८. अधिवक्ता मोहन शंकर विरुद्ध शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत^{१३२}

खास जातजाति वा वर्गको व्यक्तिलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट खर्च व्यहोरिने संस्थाबाट प्रदान हुने शिक्षा जस्तो सर्वसाधारणलाई विना भेदभाव प्रतिस्पर्धाको आधारमा र खास पिछडिएको वर्गको हकमा अझ विशेष सहूलियत दिएर पनि पहुँच दिनुपर्ने सेवालाई इन्कार गर्ने र समाजमा परम्परागत रूपमा नै शिक्षा वा राजकीय सेवामा पहुँचको हिसावको भुत्त्व वा बाहुल्य राख्ने खास खास वर्गलाई एकाधिकार दिने, ती वर्गको परम्परागत नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै सोच वा प्रयासलाई प्रष्ट रूपमा भेदभावकारी व्यवस्था वा कार्य भन्नुपर्ने ।

१९. अधिवक्ता मीना खड्का समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत^{१३३}

सरकारले निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थालाई समानताको हकसँग दाँजेर हेरी सोही आधारमा भैरहेको व्यवस्थालाई असमान भएको मानन नसकिने ।

२०. अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्के विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत^{१३४}

वहाल रहेको कानूनी व्यवस्था महिला र पुरुषबीच भेदभावपूर्ण छ भने पनि सो व्यवस्था बदरको माग नगरेको अवस्थामा कुनै कानूनी व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण भनी संशोधन गर्न आदेश दिँदा कानूनको वाध्यकारितामा प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्था संविधान स्वीकार्य पनि नमानिने ।

१३१. नेकाप २०६६, नि.नं ५३६ पृ. ५३६

१३२. नेकाप २०६६, नि.नं ८३७९ पृ. ८४८

१३३. नेकाप २०६८, नि.नं ८५५१ पृ. १८७

१३४. नेकाप २०६८, नि.नं ८५९९ पृ. ५७१

२१. निरक्षर दृष्टिविहीन सहयोग केन्द्र समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत १३५

शारीरिक अपाङ्गहरुलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गरी सक्षम बनाउनै पर्दछ । त्यसैले राज्यले समन्यायको आधारमा वितरणमुखी नीति अवलम्बन गरी पिछडिएका नागरिकहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नेपाल पक्ष भएको अनुबन्धमा भएका व्यवस्था र ऐनले प्रदान गरेको अधिकार तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालतना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । ऐनले प्रदान गरेको अधिकारहरुमध्ये कुनै एउटा अधिकार तथा सुविधाको लागि लेखी पठाउनु वा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु मात्र पर्याप्त हुदैन । लक्षित वर्गले अधिकार तथा सुविधाको उपयोग गर्न नपाएसम्म कागजमा पत्राचार गरेर वा गरिनेछ, भन्ने प्रतिवद्धता निरर्थक हुने ।

यस सम्बन्धमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिकालाई हेर्दा समानताको हक जहिलेपनि समानहरुका बीचमा आकर्षित हुन्छ । समान संरक्षण सामान्य कानूनको संरक्षण हो । व्यक्तिहरु बीच विभेद गर्नेगरी बनाएको कानूनको उद्देश्य र गरिएको वर्गीकरण वैधानिक र बोधगम्य हुनुपर्दछ, सकारात्मक विभेदलाई भेदभाव भन्न मिल्दैन, वर्ग भन्नाले आर्थिक रुपमा वर्ग मात्र नभई सबै प्रकारका वर्ग पर्दछन् । कानून बनाएर मात्र विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ, भएका अवसरहरुबाट बञ्चित गरिन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक विभेद भन्न नमिल्ने, जातिपाती, छुवाछुत साथै अन्धा, अपाङ्ग बहिरा तथा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिहरुलाई शिक्षण संस्था र तालिम केन्द्रमा निशुल्क भर्ना गरी सेवा शुल्क नलिनु भन्ने जस्ता निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पाइन्छ ।

समानतामा लैङ्गिक न्यायको सवालमा सर्वोच्च अदालत संवेदनशील देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको संरक्षणको रुपमा खेलेको भूमिका सकारात्मक देखिन्छ, ता पनि एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशहरुको कार्यन्वयन अवस्था सन्तोष जनक देखिँदैन । अदालत न्यायको अन्तिम थलो हो । अदालतले दिएको आदेश र निर्देशन कार्यन्वयन नहुने हो भने त्यसको अर्थ पनि रहन्छ । यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

१३५. नेकाप २०६८, नि.नं ८६०२ पृ. ६७६

परिच्छद-५

समस्या, निष्कर्ष र सुझाव

५.१ समस्याहरू:

- 1= बालक, वृद्ध, अपाङ्ग शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरूको विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ तर यिनीहरूलाई अन्य वर्गबाट अलग गरिएको छैन ।
- 2= संरक्षण र सशक्तिकरण कहिले सम्म गरिसक्ने हो समय सीमाको अभाव देखिन्छ ।
- 3= वर्गा विशेषलाई कानून द्वारा विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा सबै वर्गलाई समेतले गरी कानून निर्माण हुन नसक्नु,
- 4= वर्ग भित्रका सभ्रान्त (Elite) एवं शासन सत्तामा पहुँच भइरहेको र हुन सक्ने व्यक्तिहरूपनि स्वतः समावेश हुन पाउने हुँदा सभ्रान्त वर्गले नै बढी सुविधा पाउन जाने देखिन्छ ।
- 5= समानताको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ठोस संयन्त्रको अभाव देखिएवाट कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको पाइयो ।
- 6= सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तद्वारा अभिप्रेरित भएका कानूनी व्यवस्थाहरूमा एकरूपता पाइदैन ।
- 7= सकारात्मक विभेद सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानले नसमेटिएका उच्च वर्ग भनिएका वर्गभित्र पनि लाखौं संख्यामा नागरिकहरू आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक दृष्टिले पिछ्छाडिएका तथा गरिवीका अस्थामा बाचिरहेका छन् । उनीहरूलाई वर्गिक हिसाबले गरिएको परिभाषा अन्तर्गत उच्च वर्ग भित्र समावेश गर्दा अन्याय पर्न जाने देखिन्छ ।
- 8= नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले समानता र सकारात्मक विभेदको दर्शनलाई आत्मसात गरेको छ । नेपालको यथार्थलाई सम्बोधन गर्नका लागि संवैधानिक प्रावधान अझ प्रष्ट हुनुपर्ने । वर्गा र पिछ्छाडि परेको व्यक्तिको परिभाषा गरेको पाइन्दैन र संविधानले व्यवस्था गरेको वर्ग र व्यक्तिको संरक्षण सशक्तिकरण र विकासको लागि भएका कानूनी व्यवस्था पर्याप्त देखिंदैन ।
- 9= आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक रूपले पिछ्छाडिएको वर्ग भन्नाले कुन कुन वर्गलाई जनाउँछ र त्यसको पहिचानको आधार के के हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा संविधान मौन रहेको र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाट पनि सो कुरा हालसम्म प्रष्ट हुन सकेको देखिंदैन ।
- 10= पूर्ण न्याय प्रदान गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिए तापनि सर्वोच्च अदालत मावन अधिकारको संरक्षणमा सवाल सकारात्मक कानून (Positive Law) भन्दा माथि उठ्न सकेको देखिंदैन, मौलिक हक संरक्षण गर्ने सवालमा सर्वोच्च अदालत कानूनका अक्षर भन्दा बाहिर जान सकेको छैन ।
- 11= सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश, निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन ।

५.२ निष्कर्ष:

समानता मानव अधिकार हो । कानूनको अगाडि समानता औपचारिक समानता हो । परिणाममा समानता सकारात्मक विभेद हो । समानता र सकारात्मक विभेद आधुनिक समयका स्वीकृत आदर्श तथा मान्यता हुने । यी मान्यताहरूलाई मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले यसका पक्ष राज्यको आधारभूत दायित्वका रूपमा राखेका छन् । सकारात्मक विभेद सारवान समानता कायम प्राप्त गर्ने एक साधन हो । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकाससँगै यसको पनि विकास भएको मानिन्छ ।

सकारात्मक विभेदका पक्ष र विपक्षमा आ-आफ्नै विचारहरु व्यक्त भएको पाइन्छ । यसको पक्षमा रहनेहरु ऐतिहासिक रुपमा समाजका अल्पसंख्यक, कमजोर र पिछ्छडिएका वर्गका व्यक्तिहरु माथि समाजका हुनेखाने र सामन्ती वर्गका व्यक्तिहरुबाट अन्याय हुदै आएको हुँदा उनीहरुका लागि क्षतिपूर्ति स्वरुप यस किसिमका विशेष सुविधा प्रदान गरिनु आवश्यक हुन्छ । सार्थ समाजको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको वर्गका व्यक्तिहरुमा लागेको घाउमा मलहम पट्टी लगाउनु मानवीय धर्म समेत हो भन्ने उनीहरुको विचार रहेको छ । यसको विपक्षमा रहनेहरुका अनुसार समाजका अल्पसंख्यक, कमजोर र पिछ्छडिएका वर्गका व्यक्तिहरुका लागि ऐतिहासिक भूल वापत हाल क्षतिपूर्ति तिर्न वाध्य सबैका पुर्खाले त्यो ऐतिहासिक भूल गरेकै भएपनि त्यो ऐतिहासिक भूल सुधार वर्तमानमा अर्को भूल गरेर गर्न हुँदैन । साथै यसले कानूनको शासन र समानताको हकको खिल्ली उठाउने कार्य गर्दछ ।

यसरी यसको पक्ष र विपक्षमा आ आफ्नो विचार व्यक्त भएको पाइए तापनि एउटा मानवलाई दुःख पर्दा अर्को मानवले सहयोग गर्नु मानवीय धर्म भएकोले यसलाई त्यसै रुपमा लिनुपर्ने अर्को थरीको विचार वर्तमानमा बढी प्रभावकारी मान्न सकिन्छ । हामीकहाँ २०४७ सालको संविधानले सर्वप्रथम सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको थियो भने २०६३ सालको संविधानले समेत यसलाई निरन्तरता दिएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ उपधारा मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित गरिने छैन भन्ने वाक्यांश र धारा ५१ को उपधारा समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा रीती तथा संस्कारका नाम मा हुने सबै प्रकारका विभेद असमानता र शोषणको अन्त्य गर्ने । तर पनि समाजका अल्पसंख्यक, कमजोर र पिछ्छडिएका वर्गका व्यक्तिहरुको हित संरक्षणका लागि राज्यका तर्फबाट खासै ध्यान दिएको भने पाइँदैन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ र निजामति सेवा -दोश्रो संशोधन) ऐन, २०६४ मा पिछ्छडिएका वर्गका व्यक्तिहरुका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भए तापनि उनीहरुका लागि प्रदान गर्न सकिने अन्य छुट, सुविधा र उन्मुक्ति एवं उनीहरुको सशक्तिकरण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने तर्फ राज्यको खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । यस तर्फ राज्यको ध्यान जानु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।

विभेद गर्नु त्यसै पनि नकारात्मक हो । किन भने मौलिक मानव अधिकारको रुपमा मानिस समानताको हकको प्रशस्त अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिक व्यवस्थापनहरु तथा राष्ट्रिय संविधान र विभिन्न कानूनहरुद्वारा यसको प्रत्याभुति पनि गरिएको हुन्छ । तर अर्को शास्वत सत्य के हो भने दुई वा दुई भन्दा बढी मानिस, प्राकृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, हैसियत, क्षमता सोचाई रहर आदिका कारण कहिल्यै समान हुँदैनन् । समान हुँदैन भनेर मान्दा पनि असमानताको खाडल यति गहिरो र व्यापक हुन पुग्दछ कि सामाजिक नैराश्यता, विद्वेष, कलह, विद्रोह, आदिले जन्म लिन पुग्दछ । तसर्थ यस्तो असमानतालाई अर्को वर्ग समान गर्न कहिले काही दोश्रो वर्गको र पहिलो वर्गको पक्षमा भेदभाव पूर्ण व्यवहार आवश्यक हुन्छ । यो विभेद गर्नु नराम्रो पक्ष भएपनि सकारात्मक नै मानिन्छ ।

समानताको सिद्धान्तहरु मध्ये व्यक्ति व्यक्तिबीचको औपचारिक समानता समानताको एक पक्ष हो र समूह समूह बीचको सारभूत समानता अर्को पक्ष हो । यसै समूह समानताको धारणको फलस्वरुप सकारात्मक विभेदको धारणाले जन्म लिएको हो, कारण एउटा समूहलाई समवेश, वाहेक, रोकावट, वा विशेष छुट दिएर अर्को समूह समान गराउने प्रयास गरिन्छ । यसै समूहमा रहेका विभेद निराकरणको लागि अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ । साथै समानताको अनुसरण गर्दै सामाजिक न्यायको लागि पृष्ठपोषणको काम गर्दछ । यस अर्थमा हेर्दा संविधान भित्रैबाट समाजमा रहेको असमानताको स्थिति हटाउने वैधानिक संयन्त्रको रुपमा यसलाई हुर्नपर्दछ ।

विधिशास्त्री डायसीद्वारा परिवर्तित कानूनको अगाडि समानताको परम्परागत दृष्टिकोणले केवल समानता, स्वेच्छाचारिता, कानूनको समान संरक्षण आदिलाई कानूनको शासन सम्बन्धी सिद्धान्त अन्तर्गत समेटेदछ भने यस सम्बन्धी नवीनतम् धारणाले, समानता, पहुँच, सहजता र सारभूत समानतालाई समेटेदछ तसर्थ सकारात्मक विभेद मूलभूत रुपमा सशक्तिकरणको अवधारणा हो । जसमा कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई पिछ्छडिएको स्थितिबाट प्रतिस्पर्धाको लागि तोकिएको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्‍याइन्छ ।

समानता बहुआयमिक र बहुक्षेत्र प्रभावी अवधारणा हो । सामान्यतया मौलिक हकहरु मध्येको एउटा हक रुपमा समानताको हकलाई लिइए पनि समानताको प्रथम प्रत्याभूति विना अन्य हकहरु निरर्थक हुन्छन् । स्वयं न्याय तथा कानूनी राज्यको अवधारणाको प्रमुख शर्त समानता नै हो ।

राज्यद्वारा निर्मित कानून तथा त्यसको प्रयोगमा मानिस मानिसका बीच जात, जाति लिंग भाषा, धर्म, आर्थिक हैसियत, बैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने मान्यता नै कानूनको दृष्टिमा समानताको अवधारणा हो । तर प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक शैक्षिक, आदि जस्ता तत्वका आधारमा मानिसहरु यसरी विभाजित छन् कि मानिस मानिस वा समूह समूहबीच रहेको विशाल दूरीमा समानताको प्रत्याभूति र प्रयोग सम्भवै हुँदैन । त्यसैले शुद्ध समानता सम्बन्धी अवधारणालाई परम्परागत, यान्त्रिक, औपचारिक अवधारणाको रुपमा लिइन्छ । यसरी असमान स्थिति र परिस्थितिमा रहेका मानिस तथा समूहहरु बीच असमानता लायिग असमान र समानता लागि समान व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ, यसलाई पनि समान व्यवहार नै भन्ने गरिन्छ । कानूनको समान संरक्षणको शब्दावलीबाट जनाईने यस्तो अवधारणाले अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधनमा सर्वप्रथम वैधानिक रुप धारणा गरेको हो । यी दुई आयामहरुलाई वेग्लै किसिमले प्रस्तुत गर्ने गरिए पनि यी दुवै प्रावधान अन्तर्गत हुने संवैधानिक प्रत्याभूतिको प्रकृति र क्षेत्र समान नै हुन्छ । कुनै एक मात्रको प्रयोगले समानता सम्बन्धी अवधारणाको कुनै अन्य पाटोलाई नसमेट्ने भन्ने हुँदैन ।

समानता सम्बन्धी अवधारणा अहिले नया आयाममा विकसित हुँदै गैरहेको पाइन्छ । यसको शुद्ध प्रयोगले समाजमा आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक प्राकृतिक दृष्टिले पिछ्छडिएका र कमजोर वर्गले वास्तविक समानताको अनुभूतिगर्न नसक्ने हुँदा, एवं श्रोत र साधनमा उनीहरुको पहुँच नै नहुने भएकोले यस्ता वर्गको हकमा विशेष सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता बढ्दै गैरहेको छ । यस्ता पिछ्छडिएको र कमजोर वर्गको उत्थान र प्रगतिका लागि राज्यले विवेकसम्मत र न्यायिक आधारमा वर्ग पहिचान (Classification) गरी विशेष सुरक्षा, सुविधा, छुट आदि प्रदान गर्नु पर्दछ, भनिन्छ । जसलाई सकारात्मक विभेदको नीति, संरक्षणवादी नीति जस्ता केयन शब्दावलीबाट जनाउने गरिएको पाइन्छ ।

यस नीति अन्तर्गत, रानीतिक निर्वाचन र नियुक्तिको पद, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी, शिक्षा आर्जन जस्ता क्षेत्रमा आरक्षण प्रदान गर्ने, पिछ्छडिएका तथा कमजोर वर्गको लागि सशक्तिकरण, जागरण सुविधा र छुट, कानूनी सहायता जस्ता उपायहरु प्रचलनमा आएका छन् ।

सिद्धान्त र नीतिमा जे जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिए पनि असमानताको दूरी अझ बढ्दै छ । यस उपायहरुको प्रयोगमा प्रशस्त चुनौतीहरु छन् । के कस्ता आधारमा वर्ग पहिचान विवेकसम्मत हुन्छ ? सकारात्मक विभेद के कस्ता क्षेमा के कति समयका लागि दिने भन्ने विवाद यथावतै छ । लक्षित वर्ग सँगै यही सकारात्मक विभेदको अवसरमा लालायित रही प्रतिस्पर्धा, योग्यता, क्षमता, आदिमा विश्वास नगर्ने, यसलाई अधिकारकै रुपमा दावी गर्ने लक्षित वर्गको नाउँमा टाठावाठा वर्गले (Creamy Layers) ले फाइदा उठाउने गरेको, क्षमताशील, योग्य र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने वर्गमा नैराश्यताको भावना जाग्ने जस्ता प्रशस्त चुनौतिहरु छन् ।

जे होस राज्यको मौलिक कर्तव्य समानताको सुनिश्चिता र समान व्यवहार नै हो । तथापि, सकारात्मक विभेद पनि समानताको विपरित, बैकल्पिक नीति नभै समानताको परिपूरक नीति हो । यो संवेदनशील विषय भएकोले, विवेक सम्मत, इमानदारी र सकारात्मक सोच राखी कानून निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा नै यी दुवै नीतिहरुको सफलता निर्भर रहन्छ ।

महिलाको मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र न्याय महिला मुक्ति र विकासको एउटै मूल प्रवाहमा हेरिनुपर्दछ । ऐतिहासिक कालदेखिको भेदभावलाई हटाई नयाँ समय समानताको कुरा हुने खानेको पेवा र नहुनेको मृगमरीचिका मात्रै बनिरहन सक्छ, यही धरातलीय यथार्थको हृदयगम गरेमा नै लैङ्गिक न्याय र समानता सम्भव छ ।

५.३ सुभाबहरु:

1= वालक, बृद्ध, अपाङ्गशारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त व्यक्ति तथा मानव विकास सुचाङ्कले निर्धारण गरेको सामान्य स्तरभन्दा तल रहेको वर्गको व्यक्तिको संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

2= वर्ग विभाजन गरी कानूनद्वारा विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग र सशक्तिकरण गर्नुपर्ने वर्गको उत्थान गर्नका लागि

समय सीमा तोकिनु पर्छ (जस्तो २० वर्ष, २५ वर्ष)।

3= सकारात्मक विभेदका कुनै पनि उपायहरु विशेष गरी आरक्षणको नीति अवलम्बन गर्दा वर्गीकरणमा विशेष ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ । राजनीतिक घोषणाको नीति अनुरूप महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसी बंशमा जन्म भएकै कारणले मात्र निरपेक्ष रुपमा रोजगारीको क्षेत्रमा आरक्षणको सुविधा नदिई वास्तविक अनुसन्धान, मानव विकास सुचांक जस्तो प्रविधिको तथ्यांक र वस्तुगत मूल्यांकन गरेर निश्चित आधार रेखा भन्दा मुनिका जो परम्परादेखि सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको व्यक्ति तथा वर्गलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराइनु ।

4= विशेष गरी आरक्षणको नीतिले क्षमता, योग्यतावादी (Meritarians) हरु एवं प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायमा नैराश्यता जगाउने हुँदा सामाजिक एकतामा खतत पुग्न सक्छ तसर्थ यसतर्फ विशेष सम्वेदनशील भै सकेसम्म वर्तमानमा रहेका प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र र प्रमाण भन्दा वेग्लै विशेष क्षेत्र र अवसर (पद र सुविधा) सिर्जना गरी त्यसैमा आरक्षणमा नीति लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

5= योग्यता र क्षमता आदिका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिने क्षेत्रमा तत्कालको लागि उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार निश्चित समय संख्या वा स्तरको लक्ष ताकी आरक्षण लागू गरेपनि दीर्घकालिन रुपमा प्रतिस्पर्धा मूलक वातावरण श्रृजना गर्नु नै सर्वोत्कृष्ट हुन्छ । यसका लागि लक्षित वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, सवलीकरण, सशक्तिकरण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम आदिमा प्रयास केन्द्रित गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

6= हालसम्म उपलब्ध गराइएको विभेदपूर्ण नीति कार्यान्वयनको क्षेत्रमा प्रभावकारी तथा वस्तुगत मूल्यांकन एवं अनुगमन गरेर मात्र भावी रणनीति निर्माण गर्नु पर्दछ । यसका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा पचास वर्ष भन्दा बढी समयदेखि आरक्षणको व्यवस्था लागू रहेको हुँदा त्यहाँको परिणाम र असरको वस्तुगत अध्ययन गरी यस दिशामा अधि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

7= सकारात्मक विभेदको कुनैपनि कार्यक्रम लागू गर्नु अधि वर्ग पहिचान, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने संरचनात्मक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ नीति लागू भैसकेपछि आवधिक मूल्यांकन गरी लागू भएको नीतिबाट लक्षित वर्ग तथा समाजमा कस्तो प्रभाव परेको छ अध्ययन गर्ने, निर्धारित, आधार रेखा परिणाम प्राप्त भएपछि उपलब्ध विभेदपूर्ण नीतिमा पुनरावलोकन वा समाप्ति पनि गर्दै लैजानु पर्दछ ।

8= पत्येक व्यक्ति वा वर्गले प्रत्येक क्षेत्रमा उपस्थिति जनाउनै पर्छ भन्ने होइन, क्षमता योग्यता र रुचीले जो जहाँ उपयुक्त छ त्यही सम्मानपूर्वक रहन र काम गर्न पाउने वातावरणमा जोड दिन पर्दछ । वस्तु तथा सेवाको उत्कृष्टताको लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा बृद्धि भैरहेको वर्तमान समयमा यहिनै उचित हुन्छ तसर्थ यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।

9= समारात्मक विभेद विशेषतः आरक्षणको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा लक्षित वर्गको नाउँमा समाजका टाठाबाठा तथा लक्षित वर्गभित्र आफूलाई समावेश गरी अवान्छीत लाभ लिने वर्ग (Creamy Layer) बाट अति सचेत हुनु जरुरी छ ।

10= सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक वा सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएको वर्गभित्रका साचिचकै पिछडिएको व्यक्तिको परिभाषा गर्ने कानून पनि जारी गरिहाल्नु पर्छ । उक्त कानूनले पिछडिएको वर्गको परिभाषा गर्दै मानव विकास

सूचांकले निर्धारित गरेका सामान्यस्तर भन्दा तल रहेका व्यक्तिलार्थ मात्र पिछडिएको व्यक्ति वा वर्गको रुपमा समेट्नु पर्ने हुन्छ ।

11= संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकलाई प्रभावकारी रुपमा लक्षित वर्गसम्म पुर.याउनु संगठानात्मक संजाल निर्माण गरिनु पर्दछ । यसको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको शाखा विस्तार जिल्ला सदरमुकाममा मौलिक हक कार्यान्वयन अनुगमन केन्द्र, तल्लो तहको अदालतको अधिकारक्षेत्रमा बृद्धि गर्ने जस्ता कुरा गर्नु आवश्यक छ ।

12= कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या कति छ ? राज्य संयन्त्रको कुन कुन स्थानमा उनीहरुको आवश्यकता छ ? हाल उनीहरुको जीवनस्थर के कस्तो छ ? उनीहरुका जीवनको कुन कुन पक्षलाई विकास उत्थान वं शसक्र पार्नुपर्ने छ । सोका लागि अकि समय लाग्दछ ? भन्ने जस्ता पक्षमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने र अनुसन्धानका आधारमा आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

13= समान न्याय प्रदान गर्न सक्ने गरी सर्वोच्च अदाललाई अधिकार पदान गरी स्वतन्त्र तुल्याउनु पर्छ । सर्वोच्च अदालतको पैसला आदेशहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कार्यान्वयन भए नभएको नियमिति अनुगमन गरिनुपर्छ ।

छुट्टै ऐनद्वारा प्रत्येक वर्ग जस्तै उत्पीडित क्षेत्र, आर्थिक अवस्था, असहाय नागरिक आदि जस्ता वर्ग समूहको बस्तुगत आधारमा परिभाषा गरिनु पर्छ ।

****समाप्त****